

제1장

민사소송

제1절 의 의 2

제2절 헌법과 민사소송 2

제3절 다른 소송과의 구별 3

제4절 민사소송의 이상과 신의성실의 원칙 6

제1절 의 의

민사소송이란 민사사건에 관한 소송을 말한다.

먼저, ‘민사사건’이란 민법·상법 등 사법(私法)에 의하여 규율되는 대등한 주체 사이의 신분상 또는 경제상 생활관계에 관한 사건을 말한다. 그러나 사법상의 생활관계 모두가 민사소송의 대상으로 되는 것은 아니고, 원칙적으로 법률상의 쟁송에 한정된다(법조 2조 1항). 그러므로 단순한 사실관계에 관한 다툼은 민사소송의 대상이 되지 않는다.

민사사건은 대등한 주체 사이의 법률관계에 관한 것이어야 한다. 따라서 국가가 공권력의 주체로서 우월적 지위에서 국민과의 관계에서 맺은 법률관계에 관한 분쟁은 행정소송의 대상이 될 수 있을 뿐 민사소송의 대상은 되지 않는다. 그러나 국가와 사인 간의 분쟁이라고 하여도 그것이 서로 대등한 관계에서 발생한 경우에는 민사소송의 대상이 된다.

다음으로, ‘소송’이란 법원이 사회에서 일어나는 이해의 충돌을 공정하게 처리하기 위하여 서로 대립하는 이해관계인을 당사자로 관여시켜 심판하는 절차를 말한다. 여기에는 판결절차 외에 보전처분절차, 강제집행절차, 도산절차 등도 포함되지만, 일반적으로는 소제기부터 종국판결에 이르기까지의 판결절차만을 의미한다.

제2절 헌법과 민사소송

1. 헌법의 규정

우리 헌법은 생명·신체의 자유, 재산권 등의 기본권보장을 선언하고 있는데, 이러한 기본권은 정당하고 공정한 재판을 통하여 실효성이 보장되는 것

이다. 이를 위하여 우리 헌법은 민사재판에 관하여 지도원리가 되는 몇 가지 원칙을 선언·규정하고 있는데, 재판을 받을 권리(헌법 27조 1항), 재판공개의원칙(109조), 대법원의 소송절차에 관한 규칙제정권(108조) 등이 그것이다.

2. 재판청구권과 민사소송

헌법 27조 1항은 “모든 국민은 헌법과 법률이 정한 법관에 의하여 법률에 의한 재판을 받을 권리를 가진다.”라고 규정하여 국민의 재판청구권을 기본권으로 보장하고 있다. 이는 국민에 대해서는 재판, 즉 법원에의 접근을 보장하는 것임과 동시에 법원에 대해서는 재판의 거절을 금지하는 것이다.

재판청구권은 ‘헌법과 법률이 정한 법관에 의한 재판을 받을 권리’, ‘법률에 의한 재판을 받을 권리’(헌법 27조 1항), ‘공정하고 신속한 공개재판을 받을 권리’(27조 3항, 109조), ‘평등한 재판을 받을 권리’(11조 1항) 등을 그 내용으로 한다. 이러한 재판청구권에는 민사재판청구권도 포함되므로 국가는 국민의 민사재판청구권을 보장하기 위하여 최선의 노력을 다하여야 한다. 따라서 올바른 민사재판이 이루어지도록 함으로써 국민의 기본권을 실질적으로 보장하기 위해서는 민사소송의 절차규정이 헌법원칙에 맞게 입법되어야 함은 물론이고, 민사소송을 담당하는 법관들도 각 절차규정을 헌법원칙에 따라 적용하여야 한다.

제3절 다른 소송과의 구별

1. 형사소송과의 구별

형사소송은 ‘사인(私人)에 대한 국가의 형벌권 행사에 관한 사건(형사사건)’을 대상으로 하는 점에서 민사사건을 대상으로 하는 민사소송과 구별된다.

민사소송과 형사소송은 대상과 절차를 달리하므로 민사재판에서는 형사재

판에서 확정된 사실에 원칙적으로 구속되지 아니하고, 민사법원은 증거에 의하여 형사판결에서 확정된 사실과 다른 사실을 인정할 수 있는 것이지만(대법원 1979. 9. 25. 선고 79다913 판결), 동일한 사실관계에 관하여 이미 확정된 형사판결이 유죄로 인정한 사실은 유력한 증거자료가 되므로 민사재판에서 제출된 다른 증거들에 비추어 형사재판의 사실판단을 채용하기 어렵다고 인정되는 특별한 사정이 없는 한 이와 반대되는 사실을 인정할 수 없다(대법원 2021. 10. 14. 선고 2021다243430 판결).

2. 행정소송과의 구별

행정소송은 ‘공법상의 법률관계에 관한 사건(행정사건)’을 대상으로 하는 점에서 민사사건을 대상으로 하는 민사소송과 구별된다. 행정사건과 민사사건의 구분기준에 관한 학설로는 이익설, 종속설, 주체설, 귀속설, 복수기준설 등의 대립이 있으나, 현재의 다수설은 위와 같은 여러 이론을 종합적으로 고려하여야 한다는 입장이다.

민사소송은 사법상 법률관계를 대상으로 하기 때문에, 특히 행정소송 중에 공법상 법률관계를 대상으로 하는 당사자소송(행소 3조 2호)과의 구별이 어려운 경우가 많다. 이에 행정소송규칙 19조는 ① 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 85조 2항에 따른 보상금의 증감에 관한 소송 등 손실보상금에 관한 소송, ② 납세의무 존부 확인 등 그 존부 또는 범위가 구체적으로 확정된 공법상 법률관계 그 자체에 관한 소송, ③ 도시 및 주거환경정비법 35조 5항에 따른 인가 이전 조합설립변경에 대한 총회결의의 효력 등을 다투는 소송 등 처분에 이르는 절차적 요건의 존부나 효력 유무에 관한 소송, ④ 공법상 계약에 따른 권리·의무의 확인 또는 이행청구 소송을 당사자소송의 대상으로 예시하고 있다.

행정소송을 규율하는 행정소송법은 행정사건의 특수성에 비추어 관련청구의 병합(행소 10조 2항, 15조), 피고적격의 한정(13조), 직권심리(26조), 사정판

결(事情判決)(28조) 등과 같은 특칙을 두고 있으나, 특별한 규정이 없는 사항에 관하여는 민사소송법의 규정을 준용하고 있다(8조 2항).

행정처분의 효력의 유무나 존재 여부가 민사소송의 선결문제로 심리될 수 있지만(행소 11조), 행정행위에는 공정력(公定力)이 있으므로 행정처분이 위법하더라도 그 흠이 중대하고 명백하여 당연무효라고 보아야 할 사유가 있는 경우를 제외하고는 아무도 그 흠을 이유로 행정행위의 효력을 부정하지 못한다. 따라서 행정처분의 흠이 취소사유에 불과한 때에는 처분이 취소되지 않는 한 그 처분의 효력을 부정하여 그로 인한 이득을 법률상 원인 없는 이득이라고 말할 수 없다(대법원 1994. 11. 11. 선고 94다28000 판결).

3. 가사소송과의 구별

가사소송은 민사분쟁 가운데 '신분관계'에 관한 분쟁이거나 그러한 신분관계에 밀접하게 관련된 재산, 권리 기타 법률관계에 관한 분쟁을 대상으로 하는 점에서 '재산권상의 분쟁'을 대상으로 하는 민사소송과 구별된다. 가사사건도 개인 사이의 분쟁 그 밖의 사법상의 법률관계에 관한 사건이므로 본질적으로는 민사사건이지만, 신분관계의 확정은 공익과 관련이 있고 제3자와의 사이에서도 획일적인 처리가 필요하다는 점에서 가사소송에 관하여는 가사소송법이 따로 마련되어 있다.

가사소송법은 가사사건을 가사소송사건과 가사비송사건으로 나누어 열거하고 있는데, 가사소송사건은 가사소송법 2조 1항 1호, 가사비송사건은 2조 1항 2호가 규정하고 있다. 가사소송 절차에 관하여 가사소송법은 위와 같은 가사소송의 특성에 맞추어 조정 전치주의(가소 50조), 본인 출석주의(7조), 직권조사주의(17조), 사정에 의한 항소기각의 판결(19조 3항), 기판력의 주관적 범위에 관한 특칙(21조) 등의 규정을 두고 있으나, 특별한 규정이 없는 사항에 관하여는 민사소송법을 준용한다(12조 본문). 다만 가류 및 나류 소송사건에 관하여는 민사소송법 중 변론주의에 관한 여러 규정들과 청구의 인낙에

관한 규정은 적용되지 않는 것으로 규정한다(단서).

4. 비송사건과의 구별

법원의 관할에 속하는 민사사건 중 소송절차로 처리하지 않는 사건을 비송 사건이라고 한다. 비송사건이란 형식적으로는 그 일반법인 비송사건절차법에 서 정한 사건과 그 총칙규정이 적용 또는 준용되는 사건이라고 할 수 있다.

여기에는 ① 민사비송사건(법인, 신탁, 재판상의 대위, 공탁, 법인 등기, 부부재산약정 등기 등. 비송 32조 이하), ② 상사비송사건(회사, 사채, 회사의 청산 등. 72조 이하), ③ 과태료사건(247조 이하), ④ 가사비송사건(가소 2조 1항 2호) 등이 있다.

제4절 민사소송의 이상과 신의성실의 원칙

민사소송제도는 사인(私人)의 권리보호와 사법질서의 유지를 목적으로 하여 국가가 마련한 제도이다. 따라서 민사소송제도가 이상적으로 운영되려면 ① 적정, ② 공평, ③ 신속, ④ 소송경제, ⑤ 신의칙의 이념이 지배하여야 한다.

민사소송법은 1조 1항에서 “법원은 소송절차가 공정하고 신속하며 경제적으로 진행되도록 노력하여야 한다.”라고 규정하여 전통적인 이상인 적정·공평·신속·소송경제를 천명하였고, 2항에서 “당사자와 소송관계인은 신의에 따라 성실하게 소송을 수행하여야 한다.”라고 규정하여 위와 같은 이상의 실현을 뒷받침하는 신의성실의 원칙을 선언하였다. 1항의 이상 실현이 법원의 몫이라면 2항의 신의성실의 원칙은 당사자의 몫이라고 할 수 있다.

민사소송사건을 처리하는 법원으로서는 소송절차의 모든 과정에서 위와 같은 제도의 이상이 실질적이고 조화롭게 실현될 수 있도록 유념하여 실무를 운영하여야 한다.

제2장

법 원

제1절	재판권	8
제2절	민사법원	18
제3절	법 관	21
제4절	재판연구관	22
제5절	재판연구원, 조사관	22
제6절	사법보좌관	23
제7절	법원공무원	24
제8절	사무의 분담 및 인계·인수	31

제1절 재판권

1. 사법권

가. 의 의

근대국가에서는 국가작용을 입법·사법·행정의 3권으로 구분하여 이를 각기 별개의 독립한 기관에 분담시켜 서로 견제하게 함으로써 국가권력의 집중과 남용으로 인한 국민의 자유의 침해를 막으려고 한다. 우리 헌법 101조 1항도 “사법권은 법관으로 구성된 법원에 속한다.”라고 규정하여 법원을 독립하여 사법권을 행사하는 국가기관으로 규정하고 있다.

‘입법’은 일반적 효력을 가지는 추상적 법규를 정립하는 국가작용이고, ‘행정’은 법 안에서 국가의 존립과 사회공공의 이익을 위한 국가적 목적을 구체적으로 실현하는 국가작용임에 대하여, ‘사법’은 구체적인 법적 분쟁이 발생한 경우에 당사자로부터의 소제기를 전제로 무엇이 법인가를 판단·선언함으로써 법질서를 유지하고 법적용을 확보하는 국가작용이라고 말할 수 있다.

사법과 행정은 법을 적용하고 집행하는 국가작용이라는 점에서는 같지만, 사법은 법률상 쟁송을 전제로 하여 구체적인 권리의무에 관하여 재판함으로써 법적 효과의 존부를 확정·실현하는 것을 목적으로 함에 대하여, 행정은 법을 행동의 기준으로 하여 집행하고 공공의 이익을 위하여 적극적으로 국민생활에 개입하여 현실적 결과를 형성하는 것을 목적으로 하는 점에서 다르다.

그런데 법원이 관장하는 사법권에는 위와 같은 본래적 의미의 사법작용인 좁은 의미의 재판권 외에도 사법행정권 및 사법입법권(규칙제정권)이 포함된다.

나. 좁은 의미의 재판권

‘좁은 의미의 재판권’이란 구체적인 권리의무의 존부에 관한 법률상 쟁송에 관하여 법을 해석·적용하여 권리의무의 존부를 확정·실현하는 것을 말한다. 이러한 재판권에는 민사재판권, 형사재판권, 행정재판권 등이 있다.

다. 사법행정권

(1) 총 설

‘사법행정권’이란 법관이 담당하는 심판권의 원활한 수행을 위하여 필요한 인적·물적 자원을 운영·관리하는 모든 작용에 관한 권한을 의미한다. 사법행정은 재판권의 원활하고 적정한 행사를 위한 것이기 때문에 소송과 전혀 관련이 없다고는 할 수 없으나, 그 관련이 간접적·일반적이라는 점에서 소송행위 내지 소송적 활동과 구별된다.

사법행정의 최고기관은 대법원장이다. 대법원장은 사법행정사무를 총괄하고 사법행정사무에 관하여 관계 공무원을 지휘·감독한다(법조 9조 1항). 대법원장은 사법행정의 최고기관으로서의 지위에서 대법원의 일반사무를 관장하고 대법원의 직원을 지휘·감독할 뿐만 아니라, 각급 법원 및 그 소속 기관의 사법행정사무에 관하여 직원을 지휘·감독하며(13조 2항), 판사와 법원 직원에 대한 임명권을 가진다(41조 3항, 53조).

대법원장은 사법행정사무의 지휘·감독권의 일부를 법률·대법원규칙이 정하는 바에 따라 또는 대법원장의 명으로 법원행정처장, 각급 법원의 장, 사법연수원장, 법원공무원교육원장 또는 법원도서관장에게 위임할 수 있다(법조 9조 2항). 이에 따라 대법원장이 그 권한을 위임하는 규정은 법원공무원규칙, 대법원 위임전결사항내규, 법원청사 관리내규 등의 관련 부분에서 찾아볼 수 있다.

그리고 대법원장은 법원의 조직, 인사, 운영, 재판절차, 등기, 가족관계등록, 그 밖의 법원 업무와 관련된 법률의 제정 또는 개정이 필요하다고 인정

하는 경우에는 국회에 서면으로 그 의견을 제출할 수 있다(법조 9조 3항).

한편 법원조직법은 대법원장이 의장이 되고 대법관 전원으로 구성되는 대법관회의를 두어 일정한 사항에 관하여는 그 의결을 거치도록 하고 있는데(법조 16조, 17조), 대법관회의는 ① 판사의 임명 및 연임에 대한 동의, ② 대법원규칙의 제정과 개정 등에 관한 사항, ③ 판례의 수집·간행에 관한 사항, ④ 예산 요구, 예비금 지출과 결산에 관한 사항, ⑤ 다른 법령에 따라 대법관회의의 권한에 속하는 사항, ⑥ 특히 중요하다고 인정되는 사항으로서 대법원장이 회의에 부친 사항을 의결한다.

(2) 대법원예규와 전산양식

대법원예규는 사법행정권이 문서의 형태로 행사되는 대표적 형태로, 대법원이 사무의 통일을 기하기 위하여 각급 법원에 대하여 반복적 사무의 처리 기준을 제시하는 ‘지시문서’의 일종이다(사무관리규 7조, 사무관리내규 3조). 대법원예규는 규율대상에 따라 재판사무에 관한 재판예규, 등기사무에 관한 등기예규, 가족관계등록사무에 관한 가족관계등록예규, 그 밖의 사법행정사무에 관한 행정예규로 분류할 수 있다(대법원예규문서 관리지침 2조).

대법원예규 중 정책적 사항 또는 중요사항은 대법원장의 결재로 제정되지만 일반적인 사무적 사항은 대법원장의 위임을 받은 법원행정처장의 결재로 제정된다. 재판예규는 재판사무의 통일이 요구되는 업무영역에서 사무처리 의 일반적 기준으로서 제정되는 것이므로 재판사무를 담당하는 법관 및 법원직원으로서서는 반드시 그 내용을 숙지하고 실무운영에 적극 반영함으로써 재판사무가 통일적으로 처리될 수 있도록 노력하여야 한다.

또한 재판사무의 통일적이고 효율적인 처리를 위해서는 문서양식을 정형화하여 사용하는 것이 요망된다. 재판사무에 관한 문서양식은 대법원 재판예규인 ‘재판사무에 관한 문서의 양식에 관한 예규’에 따라 모두 ‘전산양식’으로 재판사무시스템의 재판양식조회[CSS201-01]에 등록되어 통일적으로 관리되고 있다.

라. 사법입법권

대법원은 법률에 저촉되지 아니하는 범위 안에서 소송에 관한 절차, 법원의 내부규율과 사무처리에 관한 규칙을 제정할 수 있다(헌법 108조). 헌법 이외와 같은 규칙제정권을 대법원에 부여한 취지는 삼권분립의 견지에서 사법부의 자주적 내부규율권을 보장하여 그 지위를 강화함과 동시에 기술적·합목적적 견지에서 소송에 관한 절차적 사항은 실무에 밝은 사법부 스스로 규율하는 것이 합리적이라는 데 있다.

대법원규칙은 대법관회의의 의결에 따라 대법원장이 제정하며(법조 17조 2호), 현재 법원의 조직과 운영, 인사, 재무, 재판, 등기, 공탁, 가족관계등록, 통계 등에 관하여 많은 대법원규칙이 제정되어 시행되고 있다. 대법원규칙과 법률이 경합할 경우에 효력의 우열에 관해서는 법률우위설, 동위설(同位說), 대법원규칙우위설 등이 있는데, 헌법 108조가 ‘법률에 저촉되지 아니하는 범위 안에서’ 대법원규칙의 제정을 인정하고 있으므로 법률우위설이 다수의 견해이다.

대법원의 규칙제정권은 권력분립의 견지에서 사법권의 자주성·자율성을 확보하기 위하여 부여된 것으로서, 입법권은 국회에 속한다는 원칙에 대한 예외로 인정되는 것이다. 따라서 대법원규칙은 헌법 108조의 규정에 따라 ‘소송에 관한 절차’에 대한 것으로서 ‘법률에 저촉되지 아니하는 범위 안’에 서라면, 법률의 위임이 없더라도 국민의 권리·의무에 영향을 미치는 사항을 규율할 수 있다고 해석된다. 이러한 점에서 대법원규칙은 ‘법률의 위임에 따른 사항이나 법률의 집행을 위하여 필요한 사항’만을 규율하는 것에 그치는 대통령령보다 광범위한 효력을 지니고 있다.

2. 민사재판권

가. 의 의

재판권 중 민사쟁송 사건을 처리하는 권능을 민사재판권이라고 한다. 민사재판권은 권리 또는 법률관계에 관한 확인·이행·형성의 판결 및 강제집행이 주된 내용을 이루고, 부수적으로 ① 소송지휘권과 법정경찰권, ② 송달·공증사무, ③ 증인·감정인의 출석요구와 신문, ④ 증거물소지자에 대한 제출명령과 검증에 대한 수인명령 및 이에 불응한 자에 대한 제재조치 등이 그에 포함된다.

나. 민사재판권의 한계

(1) 대인적 제약

(가) 총 설

국가의 영토고권에 따라 민사재판권도 국적을 묻지 않고 우리나라에 있는 모든 자연인이나 법인에 미친다. 다만 헌법 6조 1항은 “헌법에 의하여 체결·공포된 조약과 일반적으로 승인된 국제법규는 국내법과 같은 효력을 가진다.”라고 규정하고 있으므로, 이러한 조약이나 국제관습법에 의하여 민사재판권이 면제되는 경우가 있다.

(나) 외국국가

국내법원은 원칙적으로 외국국가에 대하여 재판권을 행사할 수 없다는 것이 국제관습법이다. 따라서 국가는 외국의 법원에 원고로서 소송을 제기할 수 있으나 피고로서 다른 나라의 재판권에 복종하지는 않는다.

그러나 그 면제의 범위에 관하여는 절대적 면제설과 상대적 면제설(제한적 면제설)이 대립하고 있다. 절대적 면제설에 따르면 국가의 행위는 그 행위의 성질을 묻지 않고 항상 재판권이 면제되지만, 상대적 면제설에 따르면 국가의 행위의 성질에 따라 재판권 면제의 범위를 정하게 된다.

대법원은 종래 절대적 면제설을 취하여 외국국가를 피고로 하여 우리나라

가 재판권을 행사할 수 없다고 하였으나(대법원 1975. 5. 23. 자 74마281 결정), 그 후 견해를 변경하여 상대적 면제설에 따라 우리나라의 영토 내에서 행하여진 외국의 사법적(私法的) 행위에 대해서는, 그것이 주권적 활동에 속하는 것이거나 이와 밀접한 관련이 있어서 이에 대한 재판권의 행사가 외국의 주권적 활동에 대한 부당한 간섭이 될 우려가 있다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 외국국가를 피고로 하여 우리나라의 법원이 재판권을 행사할 수 있다고 판시하였다(대법원 1998. 12. 17. 선고 97다39216 전원합의체 판결). 다만 제3채무자를 외국으로 하는 채권압류 및 추심명령을 발령하는 재판권이나 그 추심명령에 따라 외국을 피고로 하는 추심금 소송에 대한 재판권은 해당 국가가 자신의 채무에 대하여 압류 기타 우리나라 법원에 의하여 명하여지는 강제집행의 대상이 될 수 있다는 점에 대하여 명시적으로 동의하였거나 또는 우리나라 내에 그 채무의 지급을 위한 재산을 따로 할당해 두는 등 우리나라 법원의 압류 등 강제조치에 대하여 재판권 면제 주장을 포기한 것으로 볼 수 있는 경우 등에 한하여 행사할 수 있다고 하여(대법원 2011. 12. 13. 선고 2009다16766 판결) 제3채무자를 외국으로 하는 채권압류 및 추심명령에 대한 재판권 행사는 외국을 피고로 하는 판결절차에서의 재판권 행사보다 더욱 신중히 행사될 것이 요구된다고 판시하였다. 한편 외국이 국내 부동산을 점유하는 것을 두고 반드시 주권적 활동에 속하거나 이와 밀접한 관련이 있는 사법적 행위에 해당한다고 볼 수는 없지만, 외국이 부동산을 공판지역으로 점유하는 것과 관련하여 해당 국가를 피고로 하여 제기된 소송이 외교공관의 직무 수행을 방해할 우려가 있는 때에는 그에 대한 우리나라 법원의 재판권 행사가 제한되고, 이때 그 소송이 외교공관의 직무 수행을 방해할 우려가 있는지 여부는 원고가 주장하는 청구 권원과 내용, 그에 근거한 승소판결의 효력, 그 청구나 판결과 외교공관 또는 공관직무의 관련성 정도 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2023. 4. 27. 선고 2019다247903 판결). 이러한 법리에 따라 판례는 외국이 어느 토지를 주한대사관 건물의

부지 또는 그 부속토지로 사용하고 있는 사안에서 외국을 상대로 하여 그 건물의 일부 철거 및 토지 인도를 구하는 것에 대한 우리나라 법원의 재판권 행사가 제한된다고 보았으나, 위 토지의 점유 사용으로 인한 차임 상당 부당이득반환을 구하는 것에 대해서는 우리나라 법원의 재판권이 인정될 수 있다고 보았다.

(다) 외교관

외교관의 재판권 면제는 우리나라가 가입한 1961년 ‘외교관계에 관한 비엔나협약’에 규정되어 있다. 외교관 및 그 가족은 접수국의 국민이 아닌 한 민사재판권이 면제된다. 다만 ① 접수국의 영역 내에 있는 개인 부동산에 관한 부동산 소송(외교관이 공관의 목적을 위하여 파견국을 대신하여 소유하는 경우는 제외), ② 외교관이 파견국을 대신하지 아니하고 개인의 자격으로 유언집행인, 유산관리인, 상속인 또는 유산수취인으로서 관련된 상속에 관한 소송, ③ 접수국에서 외교관이 그의 공적직무 이외로 행한 직업적 또는 상업적 활동에 관한 소송에서는 민사재판권이 면제되지 아니한다(위 협약 31조 1항).

외교관은 증인으로서 증언해야 할 의무를 지지 아니하고(위 협약 31조 2항), 민사재판권이 면제되는 경우에는 강제집행도 면제된다(3항). 그러나 외교관에 대한 재판권의 면제는 포기할 수 없는 것이 아니므로 파견국의 정부는 명시적 의사로써 이를 포기할 수 있다(32조 1항, 2항).

그리고 우리나라가 가입한 1963년 ‘영사관계에 관한 비엔나협약’에 따르면 영사관원과 사무직원은 그 직무수행 중의 행위에 대하여 접수국의 재판권이 면제된다(위 협약 43조 1항). 그러나 영사관원 또는 사무직원이 체결한 계약으로서 그가 파견국의 대리인으로서 명시적으로 또는 묵시적으로 체결하지 아니한 계약으로부터 제기되는 민사소송이나, 접수국 내의 차량, 선박 또는 항공기에 의한 사고로부터 발생하는 손해에 대하여 제3자가 제기하는 민사소송에 대하여는 민사재판권이 면제되지 아니한다(2항).

(라) 주한미군

주한미군에 대한 민사재판권에 관하여는 ‘대한민국과 아메리카합중국 간의 상호방위조약 제4조에 의한 시설과 구역 및 대한민국에서의 합중국 군대의 지위에 관한 협정(SOFA)’이 규정하고 있다.

위 협정에 따르면 주한미군의 구성원 및 고용원(주한미군에 배속된 한국군인 포함)의 공무집행 중의 불법행위에 관하여는 우리나라의 민사재판권이 면제된다(위 협정 23조 5항). 따라서 주한미군의 공무상의 불법행위로 인하여 한국인이 손해를 입은 경우에는 우리 국가배상법에 따라 대한민국을 피고로 제소하여야 한다(대한민국과 아메리카합중국 간의 상호방위조약 제4조에 의한 시설과 구역 및 대한민국에서의 합중국 군대의 지위에 관한 협정의 시행에 관한 민사특별법 2조).

그러나 주한미군의 구성원 및 내국인 아닌 고용원의 공무집행과 관련 없는 불법행위로 인하여 손해를 입었을 경우에는 우리나라의 민사재판권이 미친다(위 협정 23조 6항, 7항, 9항). 다만 이 경우에도 먼저 대한민국 당국의 배상금의 사정과 주한미군 당국의 배상금지급제의를 기다려 이에 불복이 있는 경우에 한하여 주한미군을 상대로 우리나라 법원에 소를 제기할 수 있다(6항). 전시 또는 비전시이든 계약으로 인한 분쟁에 대해서는 민사소송에 의하여 해결하는 외에 조정을 위하여 합동위원회에 회부할 수 있다(10항).

(마) 국제기구

국제기구의 재판권 면제에 관한 국제적 합의는 성립되어 있지 않으나, 대한민국이 당사자인 조약에 따라 재판권 면제가 적용될 수 있다.

(2) 대물적 제약(국제재판관할권)

국제사법은 국제재판관할에 관하여 2조 1항에서 “대한민국 법원은 당사자 또는 분쟁이 된 사안이 대한민국과 실질적 관련이 있는 경우에 국제재판관할권을 가진다. 이 경우 법원은 실질적 관련성의 유무를 판단할 때에 당사자 간의 공평, 재판의 적정, 신속 및 경제를 꾀한다는 국제재판관할 배분의 이

념에 부합하는 합리적인 원칙에 따라야 한다.”라고 규정하고, 2조 2항에서 “이 법이나 그 밖의 대한민국 법령 또는 조약에 국제재판관할에 관한 규정이 없는 경우 법원은 국내법의 관할 규정을 참작하여 국제재판관할권의 유무를 판단하되, 제1항의 취지에 비추어 국제재판관할의 특수성을 충분히 고려하여야 한다.”라고 규정하고 있다.

그러므로 법원은 당사자 간의 공평, 재판의 적정, 신속 및 경제를 기한다는 기본이념에 따라 국제재판관할을 결정하여야 하고, 구체적으로는 소송당사자들의 공평, 편의 그리고 예측가능성과 같은 개인적인 이익뿐만 아니라 재판의 적정, 신속, 효율 및 판결의 실효성 등과 같은 법원 내지 국가의 이익도 함께 고려하여야 하며, 이러한 다양한 이익 중 어떠한 이익을 보호할 필요가 있는지 여부는 개별 사건에서 법정지와 당사자의 실질적 관련성 및 법정지와 분쟁이 된 사안과의 실질적 관련성을 객관적인 기준으로 삼아 합리적으로 판단하여야 한다(대법원 2005. 1. 27. 선고 2002다59788 판결, 대법원 2021. 3. 25. 선고 2018다230588 판결).

한편 국제사법은 2조에서 국제재판관할에 관한 일반원칙을 규정하고 있는 외에 3조 이하에서 일반관할 및 특별관할의 구체적인 재판관할규정을 마련하고 있다. 즉 대한민국에 일상거소(habitual residence)가 있는 사람이나 주된 사무소·영업소 또는 정관상의 본거지나 경영의 중심지가 대한민국에 있는 법인 또는 단체와 대한민국 법에 따라 설립된 법인 또는 단체에 대한 소에 관하여는 법원에 국제재판관할이 있다는 일반원칙을 규정하면서(국제사법 3조 1항, 3항), 사무소·영업소 소재지 등의 특별관할(4조), 재산소재지의 특별관할(5조), 관련사건 관할(6조), 반소관할(7조), 합의관할(8조), 변론관할(9조), 전속관할(10조)에 관한 규정을 두고 있다. 나아가 각칙에서도 사건 유형별로 특별관할에 관한 규정을 두고 있다(24조, 25조, 38조, 39조, 41조 내지 44조, 56조 내지 62조, 76조, 79조, 89조 내지 93조).

위와 같이 국제사법 개정으로 국제재판관할에 관하여 일반원칙 외에도 구

체적 재판관할규정이 마련되었으므로, 관련 규정들을 종합적으로 고려하여 개별 사건에서의 국제재판관할의 유무를 판단하여야 한다. 한편 위 일반원칙 등에 따라 국제재판관할이 있더라도 이를 행사하기에 부적절하고 외국법원이 분쟁을 해결하기에 더 적절하다고 판단되는 경우에는 피고의 신청에 따라 국제재판관할권을 행사하지 않을 수 있게 되었으므로(국제사법 12조 1항 참조), 유의하여야 한다.

(3) 장소적 제약

민사재판권은 영토고권의 원칙에 따라 우리나라에만 미치고 외국에서 행사할 수는 없다. 따라서 외국과의 사법공조협정이 없는 한 외국에서 소송서류를 송달하거나 증거조사를 할 수는 없다. 자세한 내용은 제40장(국제민사사법공조) 참조.

다. 민사재판권이 없을 때의 효과

민사소송에서 민사재판권의 존재는 소송요건이고 공익성이 강하므로 직권 조사사항이다. 재판권이 없으면 소는 부적법하다.

재판권 없음이 명백하면 이는 소장의 부분을 송달할 수 없는 경우에 해당하므로 재판장의 명령으로 소장을 각하한다(민소 255조 2항, 254조 2항). 그러나 재판장이 소장을 심사하는 단계에서 재판권 면제자에 대한 소제기인 것이 분명하더라도 외국국가의 경우 대법원판례(대법원 1998. 12. 17. 선고 97다39216 전원합의체 판결)에 따르면 사법적(私法的) 행위에 대하여는 그 행위가 주권적 활동에 속하는 것이거나 이와 밀접한 관련이 있어서 이에 대한 재판권의 행사가 외국의 주권적 활동에 대한 부당한 간섭이 될 우려가 있다는 등의 특별한 사정이 없는 한 우리나라의 법원이 민사재판권을 행사할 수 있으므로 재판권의 존부에 관하여 조사하여야 하고, 그 밖의 경우라도 재판권 면제를 포기할 여지가 있을 경우에는 소장을 바로 각하할 것은 아니고 소장을 송달하는 등의 방법으로 소제기 사실을 알린 다음 재판권의 존부를

판단하여야 할 것이다. 그리고 재판권의 존부에 관한 조사 결과 재판권이 없다고 판단되면 판결로 소를 각하하여야 할 것이다.

국제사법에 따라 국제재판관할이 있는 경우에도 법원이 국제재판관할권을 행사하기에 부적절하고 국제재판관할이 있는 외국법원이 분쟁을 해결하기에 더 적절하다는 예외적인 사정이 명백히 존재할 때에는 피고의 신청에 의하여 법원은 본안에 관한 최초의 변론기일 또는 변론준비기일까지 소송절차를 결정으로 중지하거나 소를 각하할 수 있다. 다만 당사자가 합의한 국제재판관할이 법원에 있는 경우에는 그러하지 아니하다(국제사법 12조 1항).

재판권이 없음을 간과한 본안판결에 대하여는 상소에 의하여 다룰 수 있고, 판결이 확정된 뒤에는 재심사유가 아니므로 재심의 소를 제기할 수는 없으나, 재판권 면제자에 대하여는 기판력·집행력 등 판결의 내용상 효력이 생기지 않으므로 그와 같은 의미에서 무효의 판결이라고 할 것이다.

제2절 민사법원

1. 법원의 의의

법원은 넓은 의미로는 재판권을 행사하는 국가기관을 총칭하는 것으로서, 재판기관뿐 아니라 법원직원(법조 53조)을 포함한 복합적인 기관을 말한다. 이는 ‘사법행정상 법원’ 또는 ‘조직법상 법원’이라고도 하는데, 일반적으로 법원조직법 등에서 법원이라고 하는 경우에는 넓은 의미의 법원을 말한다.

좁은 의미에서의 법원은 사법권 중 고유의 재판사무를 처리하기 위하여 한 사람 또는 여러 사람의 법관으로 구성된 재판기관을 말한다. 이는 ‘소송법상 법원’이라고도 하는데, 일반적으로 민사소송법 등에서 법원이라고 하는 경우에는 좁은 의미의 법원을 말한다.

2. 조직법상 법원

조직법상 법원은 최고법원인 대법원과 각급법원으로 조직된다(헌법 101조 2항). 대법원 이외의 각급 법원은 고등법원·특허법원·지방법원·가정법원·행정법원·회생법원으로 분류된다. 그리고 지방법원 및 가정법원의 사무의 일부를 처리하기 위하여 그 관할구역 내에 지원과 가정지원, 시·군법원 및 등기소를 둘 수 있다(법조 3조 1항, 2항).

3. 소송법상 법원

가. 총 설

소송법상 법원인 재판기관은 수소법원으로서 소송사건을 접수·심리·판단하는 기능을 하고, 또한 집행법원으로서 스스로 일정한 강제집행을 실시하거나 집행관의 강제집행실시를 감독하는 기능을 한다.

나. 합의제와 단독제

재판기관은 한 사람의 법관으로 구성하는 경우와 여러 사람의 법관으로 구성하는 경우가 있는데, 전자를 단독제, 후자를 합의제라고 한다. 대법원과 고등법원의 경우는 합의제를 채택하고 있으나, 지방법원은 단독제를 원칙으로 하면서 합의제를 병용하고 있다(법조 7조 4항, 32조). 법조경력 10년 미만인 판사는 변론을 열어 판결하는 사건에 관하여는 단독으로 재판할 수 없는 것이 원칙이나, 각급 법원에 위 기준을 충족하는 판사가 부족하여 재판업무 수행에 중대한 차질이 우려되는 등 불가피한 경우에는 대법원장은 기간을 정하여 그 소속 판사로 하여금 위 제한을 받지 아니하고 단독으로 재판할 것을 허가할 수 있다(42조의3 1항, 3항). 지방법원·가정법원·행정법원·회생법원의 합의부와 고등법원·특허법원 재판부는 3인의 법관으로 구성된다(7조 3항, 5항). 대법원의 심판권은 원칙적으로 대법관 전원의 3분의 2 이상으로 구성되는 합의체에서 행사한다. 다만 대법관 3명 이상으로 구성된 부에

서 사건을 먼저 심리하여 의견이 일치한 때에는 일정한 경우를 제외하고는 그 부에서 재판할 수 있다(1항).

다. 재판장·수명법관·수탁판사

합의심판은 헌법 및 법률에 다른 규정이 없으면 합의부의 과반수로 결정한다(법조 66조 1항). 그러나 합의부의 모든 직무를 합의에 의하여 결정한다면 절차의 번잡과 소송의 지연을 초래할 염려가 있으므로 일정한 행위는 재판장 또는 수명법관이 하는 경우가 있다.

고등법원 부의 재판장은 그 부의 구성원 중 1인이 되고, 지방법원 부의 재판장은 그 부에 속한 부장판사가 되지만(법조 27조 3항, 30조 2항, 3항), 지방법원이 특별한 사정이 있어 부장판사가 아닌 판사 3인으로 합의부를 구성한 경우에는 그중 한 사람이 재판장이 된다(사무분담·사건배당예규 3조 2항 단서). 다만 법조경력 10년 미만인 판사는 합의부의 재판장이 될 수 없다(법조 42조의3 2항).

재판장은 합의부의 대표자격으로 소송지휘권, 법정경찰권, 증인신문에 관한 권한, 판결의 선고 및 석명권을 행사한다(민소 135조 내지 137조, 206조, 327조, 법조 58조 등). 변론의 지휘나 석명권 행사에 관한 재판장의 명령 또는 조치에 대하여 당사자가 이의를 신청한 때에는 합의부가 결정으로 그 이의신청에 대하여 재판한다(민소 138조).

또한 수명법관의 지정, 법원이 하는 각종 촉탁, 기일지정, 공시송달명령, 소장심사·소장각하명령, 변론준비절차회부 등 합의부 구성원 전원이 관여할 필요가 없는 사항에 관하여는 재판장이 단독으로 그 권한을 행사한다(민소 139조 1항, 2항, 165조, 194조, 254조, 258조). 이와 같이 재판장이 단독으로 한 행위에 대하여는 그 불복이 허용되는 한 상급법원에 항고할 수 있다(254조 3항, 439조).

합의부를 대표하여 법이 정한 일정한 사항에 관하여 소송행위를 하는 합

의부원(재판장 포함)을 ‘수명법관’이라고 한다. 수명법관의 지정은 재판장이 하고(민소 139조 1항), 수명법관에게는 화해의 권고, 변론준비절차의 진행, 법원 밖에서의 증거조사, 일정한 경우의 증인신문, 조정 등을 맡길 수 있다(145조, 280조 3항, 297조 1항, 313조, 민조 7조 5항, 9조 3호).

‘수탁판사’란 법원 사이에서 어느 법원이 다른 법원에 일정한 재판사항의 처리를 위탁한 경우에 그 처리를 맡은 다른 법원의 단독판사를 말한다(민소 145조 1항, 297조 등). 수탁판사가 한 처분 또는 재판은 소송법상 재판장이나 수명법관이 한 것과 마찬가지로 취급된다.

수명법관이나 수탁판사의 재판에 대하여 불복이 있으면 당사자는 그 재판이 수소법원의 재판인 경우로서 항고할 수 있는 때에 한하여 수소법원에 이의를 신청할 수 있다(민소 441조 1항).

제3절 법 관

사법권은 법관으로 구성된 법원에 속한다(헌법 101조 1항). 법원조직법은 대법원에 대법관을 둔다고 규정하는 한편(법조 4조 1항), 대법원장과 대법관이 아닌 법관을 판사로 한다고 규정하고 있으므로(5조 1항), ‘법관’이라 함은 대법원장·대법관 및 판사를 총칭하는 말이다.

대법원장과 대법관 및 판사의 임명자격은 법률로 정해져 있고(법조 42조), 대법원장은 국회의 동의를 받아 대통령이 임명하며, 대법관은 대법원장의 제청으로 국회의 동의를 받아 대통령이 임명하고, 판사는 인사위원회의 심의를 거치고 대법관회의의 동의를 받아 대법원장이 임명한다(41조).

판사는 일정년수 이상 법조경력을 가진 사람 중에서 임용하는데, 2017년까지는 3년 이상의 법조경력자 중에서 임용하였고, 그 후부터는 5년 이상의 법조경력자 중에서 임용한다. 20년 이상 법조경력을 가진 사람 중에서 특정

재판사무만을 담당하는 판사를 임용할 수 있다(법조 42조 2항).

제4절 재판연구관

대법원에는 사건의 심리 및 재판에 관한 조사·연구 업무를 담당하는 재판연구관을 둔다(법조 24조 1항, 2항). 재판연구관은 판사로 보하거나 3년 이내의 기간을 정하여 판사가 아닌 사람 중에서 임명할 수 있는데, 판사가 아닌 재판연구관은 2급 또는 3급 상당의 별정직공무원이나 국가공무원법 26조의 5에 따른 임기제공무원으로 한다(3항, 4항). 대법원장은 다른 국가기관 등에 대하여 소속 공무원 및 직원을 재판연구관으로 근무하게 하기 위하여 파견근무를 요청할 수 있다(5항).

제5절 재판연구원, 조사관

각급 법원에는 사건의 심리 및 재판에 관한 조사·연구, 그 밖에 필요한 업무를 수행할 재판연구원을 둘 수 있다(법조 53조의2 1항, 2항).

재판연구원은 변호사의 자격이 있는 사람 중에서 대법원장이 임용하고, 국가공무원법 26조의5에 따른 임기제공무원으로 3년의 범위 내에서 기간을 정하여 채용하며, 정원 및 직제와 그 밖에 필요한 사항은 대법원규칙으로 정한다(법조 53조의2 3항 내지 6항).

대법원과 각급 법원에는 조사관을 둘 수도 있다(법조 54조의3 1항). 조사관은 법관의 명을 받아 법률 또는 대법원규칙으로 정하는 사건에 관한 심판에 필요한 자료를 수집·조사하고, 그 밖에 필요한 업무를 담당한다(2항). 대법원장은 다른 국가기관에 대하여 그 소속 공무원을 조사관으로 근무하게 하

기 위하여 법원에의 파견근무를 요청할 수 있는데, 조사관의 자격, 직제 및 인원과 그 밖에 필요한 사항은 대법원규칙으로 정한다(3항, 4항). 대법원에는 법관인 재판연구관의 명을 받아 민사, 형사, 행정사건의 심판에 필요한 자료를 수집·조사하고 그 밖에 필요한 업무를 수행하는 전문임기제공무원인 법률조사관을 두고 있다(조사관규 2조의1). 대법원, 특허법원, 서울중앙지방법원에는 지식재산권에 관한 전문 심리를 위하여 기술조사관을 두고 있다.

제6절 사법보좌관

대법원과 각급 법원에 사법보좌관을 둘 수 있다(법조 54조 1항).

사법보좌관제도는 사건수의 지속적인 증가 등 법원의 업무증가로 인하여 법관의 업무부담이 과중함에도 불구하고 법관의 대폭적인 증원이 현실적으로 불가능한 실정에서 법관을 실질적 쟁송에 관한 업무에 집중시키고 실질적 쟁송에 해당하지 아니하는 부수적인 업무와 공증적 성격의 사법업무는 상당한 경력과 능력을 갖춘 사법보좌관으로 하여금 처리하도록 함으로써 국민경제적으로 예산을 절감하고 사법자원을 합리적으로 배분하기 위하여 도입된 것이다.

사법보좌관은 ① 민사소송법(같은 법이 준용되는 경우를 포함한다) 및 소송촉진 등에 관한 특례법에 따른 소송비용액·집행비용액 확정결정절차, 독촉절차, 공시최고절차, 소액사건심판법에 따른 이행권고결정절차에서의 법원의 사무, ② 민사집행법(같은 법이 준용되는 경우를 포함한다)에 따른 집행문 부여 명령절차, 채무불이행자명부 등재절차, 재산조회절차, 부동산에 대한 강제경매절차, 자동차·건설기계에 대한 강제경매절차, 동산에 대한 강제경매절차, 금전채권 외의 채권에 기초한 강제집행절차, 담보권 실행 등을 위한 경매절차, 제소명령절차, 가압류·가처분의 집행취소신청절차에서의 법원의 사무,

③ 주택임대차보호법 및 상가건물 임대차보호법상의 임차권등기명령절차에서의 법원의 사무, ④ 가사소송법에 따른 상속의 한정승인·포기 신고의 수리와 한정승인취소·포기취소 신고의 수리절차에서의 가정법원의 사무, ⑤ 미성년 자녀가 없는 당사자 사이의 가족관계의 등록 등에 관한 법률에 따른 협의이혼절차에서의 가정법원의 사무 중 대법원규칙이 정하는 업무를 수행한다(법조 54조 2항, 사법보좌관규 2조 1항).

사법보좌관은 법관의 감독을 받아 업무를 수행하며, 사법보좌관의 처분에 대하여는 대법원규칙으로 정하는 바에 따라 법관에게 이의신청을 할 수 있다(법조 54조 3항).

사법보좌관은 법원사무관·등기사무관 이상의 직급으로 5년 이상 또는 법원주사보·등기주사보 이상의 직급으로 10년 이상 근무한 사람 중 대법원규칙이 정하는 사람으로 하며, 사법보좌관의 직제 및 인원 그 밖에 필요한 사항은 대법원규칙으로 정한다(법조 54조 4항, 5항).

제7절 법원공무원

1. 법원공무원의 지위

가. 총 설

법원조직법에 따르면 ‘법원공무원’이라는 표현은 법관 및 법원직원을 모두 포함하는 용어이다(법조 53조 참조). 그러나 주요 대법원규칙(법원공무원규칙, 법관 및 법원공무원수당 등에 관한 규칙, 법원공무원 정원에 관한 규칙 등)이나 일반 용례(법원공무원교육원 등)에서 법원공무원은 ‘법원직원’만을 의미하는 표현으로 널리 사용되고 있으므로, 법원실무제요에서도 특별한 경우가 아니면 이러한 관용적인 표현방법에 따르기로 한다.

나. 임 명

법원조직법에 따르면 법관 이외의 법원공무원은 대법원장이 임명하며, 그 수는 대법원규칙으로 정하도록 되어 있다(법조 53조). 그러나 국가공무원법 32조 5항의 위임에 따른 법원공무원규칙에 의하여 이와 같은 대법원장의 임용권 중 4급 이하의 법원직원에 대한 일정사항은 법원행정처장·사법연수원장·사법정책연구원장·법원공무원교육원장·법원도서관장·고등법원장·특허법원장·지방법원장·가정법원장·행정법원장·회생법원장에게 위임되어 있고, 5급 이하의 법원직원에 대한 일정사항은 사무국을 둔 지원의 지원장에게 위임되어 있다(법원공무원규 5조 1항 및 별표 3).

다. 지 위

법원공무원 역시 국가공무원이므로 국가공무원법의 적용을 받고, 그에 규정된 바에 따라 권리를 가지며 복무상 의무를 진다. 그러나 법원공무원은 다른 국가공무원에 비하여 취급하는 직무에 특수성이 있으므로 이를 규율하기 위하여 일련의 대법원규칙이 제정되어 있다. 예컨대 ① 인사에 관한 것으로는 법원공무원규칙, 법원인사사무규칙, 법원공무원 평정규칙 등이 있고, ② 보수에 관한 것으로는 ‘법관 및 법원공무원수당 등에 관한 규칙’, ‘법관 및 법원공무원 명예퇴직수당 등 지급규칙’, 법원공무원 여비 규칙 등이 있으며, ③ 복무에 관한 일반적 사항에 관한 것으로는 법원사무관리규칙, 법원감사규칙 등이 있다.

라. 직무수행

법원사무관리규칙은 법원의 사무는 용이성·정확성·신속성 및 경제성이 확보될 수 있도록 관리하여야 한다고 규정하고 있고(사무관리규 4조), 법원재판사무 처리규칙은 재판사무 등은 적정·신속하게 처리하여야 하고, 능률과 봉사를 지향하여야 한다고 규정하고 있으므로(재판사무규 3조), 법원공무원이

담당직무를 수행함에 있어서는 항상 위와 같은 원칙을 염두에 두고 사무를 처리하여야 한다. 대법원예규인 ‘재판사무 등 처리개선지침’도 재판사무 처리에 따른 대민사무를 친절, 공정, 신속, 정확하게 처리하도록 요구하고 있다.

법원공무원은 재판사무를 담당하는 경우라도 동시에 법원행정사무에 종사하는 것이므로 당연히 직무상 상관의 지휘·감독을 받게 된다. 따라서 재판사무에 관한 직무를 행함에 있어서는 법관의 지시에 따라야 하고, 행정사무에 관하여는 소속 국·과의 상관의 지휘·감독을 받게 된다.

2. 법원공무원의 직무개관

가. 총 설

법원의 사무 중에서 법원공무원이 담당하는 분야는 재판사무 가운데 재판의 내용을 형성하는 과정에 관한 절차적 사무 및 사법행정사무이다. 그런데 사법행정사무 중 예산, 청서관리 등 일반행정사무는 법원공무원에게만 특유한 사무는 아니므로, 여기에서는 사법행정사무 중 재판사무에 관련되는 부분만을 다루기로 한다.

나. 재판사무

(1) 담당자

민사소송법상 재판사무에 관여하여 재판사무를 담당하는 법원공무원은 법원서기관·법원사무관·법원주사 또는 법원주사보(이들을 합쳐 ‘법원사무관등’이라 한다)이다(민소 40조 2항). 법원이사관과 법원부이사관은 법원사무관등을 감독하는 입장에서, 법원서기와 법원서기보는 법원사무관등을 보조하는 입장에서 각각 그 소송사무를 뒷받침하는 것이고, 자기의 이름으로 소송법상 효과 있는 행위를 할 수는 없다.

(2) 직무성격의 변화

법원사무관등은 종래 조서작성에 치중된 업무를 수행하여 왔으나 2002년

개정 민사소송법과 ‘새로운 민사사건관리방식’의 시행으로 인하여 그 역할이 크게 변모되어 조서작성 업무 외에 재판장을 보조하여 사건의 진행을 관리하고 절차의 진행상황을 점검하여 재판장에게 보고하는 등 사건관리보조자로서의 역할을 담당하고 있다.

이러한 법원사무관등의 사건관리보조자로서의 역할 분담에 관하여는 민사소송규칙 5조 3항(접수된 소송서류의 보정 권고), 30조(석명권의 행사 등에 따른 법원사무관등의 조치), 65조 3항(방식에 맞는 답변서의 제출 촉구) 등에서 그 근거를 제공하고 있다.

(3) 직무의 내용

민사소송법과 민사소송규칙에 따라 법원사무관등이 담당하는 재판사무는 다양한데, 그 내용에 따라 다음과 같이 분류할 수 있다.

① 소송서류심사 및 보정권고, 보정명령: 소장·답변서·준비서면·증거신청서 등 각종 서류의 심사, 접수된 서류에 보완할 사항이 있는 경우의 보정권고, 재판장의 보정명령에 관한 사무처리 보조(민소규 5조 3항), 소장 또는 항소장심사 단계에서 이루어지는 형식적 요건(인지, 주소, 필수적 기재사항 등)에 대한 보정명령(민소 254조 1항, 399조 1항, 402조 1항)

② 재판장의 사건분류 보조: 답변서 미제출 사건의 신속한 분류 및 기록인계, 제출된 답변서의 심사 및 사건처리방향에 대한 의견 제시(민소규 65조 3항)

③ 서면공방, 석명에 따른 적시 조치: 준비명령·준비서면 발송, 제출문서의 접수와 기한관리, 제출된 준비서면의 검토 및 그 내용에 따른 적시 조치(민소규 30조, 73조)

④ 증거조사 보조: 기일전 증거신청에 대한 채부·발송·도착상황 등 점검관리, 정형적 증거신청의 점검 및 신청 촉구(민소규 70조의3), 제출 서증의 사전정리 및 중복제출 문서의 반환, 증인신문기일 전의 증인출석 가능 여부 확인 및 재판장 보고

⑤ 기일지정 관련 업무: 재판장과 협의 후 무변론판결 선고기일 및 공시송달사건의 변론기일 지정, 재판장의 위임에 따라 재판기일 등 재판부의 업무 일정 조정·관리

⑥ 소송절차상 송달·통지 업무: 송달(민소 175조), 공시송달(194조), 소송절차상의 최고·통지(민소규 3조 4항)

⑦ 조서작성 및 제증명 발급 등 업무: 조서작성(민소 153조), 소송기록의 열람·복사, 재판서·조서의 정본·등본·초본의 교부 또는 소송에 관한 사항의 증명서의 교부(162조)

⑧ 재판사무시스템의 관리: 재판사무시스템상의 각종 입력사무에 관한 최종 책임, 사건진행단계의 확인과 변경, 각종 제출기간경과목록 점검

⑨ 기록의 보관·관리: 사건진행단계별로 효율적인 기록관리

⑩ 소송비용 관련 업무: 소송비용액 확정결정 신청이 있는 경우의 소송비용액 계산(민소 115조)

(4) 법원사무관등의 처분에 대한 이의

법원사무관등의 처분에 대하여 당사자나 이해관계인은 그 법원사무관등이 속한 법원에 이의를 신청할 수 있고, 이 경우 법원은 결정으로 재판한다(민소 223조). 이의신청의 대상은 소송법상 법원사무관등의 직무로 규정되어 있는 모든 사항에 관한 처분에 미치고, 그 처분은 적극적 처분이든 소극적 처분(각하·거부 등)이든 묻지 않는다. 다만 법률이 특별히 불복신청의 절차를 따로 규정하고 있는 경우(461조의 준재심 등)에는 그 규정에 따른 별개의 절차에 의한다.

법원은 이의가 이유 있다고 인정하는 경우에는 법원사무관등의 처분을 취소하고 경우에 따라서는 상당한 처분을 명할 수 있으며, 이유가 없다고 인정하면 결정으로 이의신청을 기각한다. 기각결정에 대하여 당사자는 통상의 항고로써 불복할 수 있으나(민소 439조), 법원사무관등은 법원의 결정에 대하여 항고할 수 없다.

다. 재판사무 외의 사무

(1) 총 설

사법행정사무로서 재판사무에 관련되는 사무는 본질에 있어서 행정작용의 성질을 가지는 것이므로 반드시 법원에 의하여 처리될 필요는 없고 현행법 상으로도 그 사무의 많은 부분을 법원공무원이 담당하고 있다.

(2) 등 기

등기사무는 그 등기의 대상에 따라 법인등기(비송 60조 내지 67조 참조), 상업등기(상등 참조), 부동산등기(부등 참조), 선박등기(선박등기법 참조), 입목등기(입목에 관한 법률 참조), 부부재산 약정의 등기(비송 68조 내지 71조 참조) 등으로 구분된다.

등기사무를 처리하는 기관으로 등기소를 설치하고 그곳에 법원서기관 또는 법원사무관·등기사무관으로 보하는 등기소장을 둔다. 등기소장은 소속 지방법원장 또는 사무국을 둔 지원의 지원장의 지휘를 받아 등기소의 사무를 관장하고 그 소속 직원을 지휘·감독한다(법조 36조). 등기사무는 지방법원 및 그 지원과 등기소에 근무하는 법원서기관·등기사무관·등기주사 또는 등기주사보(법원사무관·법원주사 또는 법원주사보 중 2001. 12. 31. 이전에 시행한 채용시험에 합격하여 임용된 사람을 포함한다) 중에서 지방법원장(등기소의 사무를 지원장이 관장하는 경우에는 지원장)이 지정한 자가 처리하며, 이와 같이 지방법원장 등에 의하여 등기사무를 처리하도록 지정된 자를 ‘등기관’이라 한다(부등 11조, 상등 8조).

등기관은 독자적인 권한 아래 자기의 이름으로 등기사무를 처리하는데, 등기신청의 적부에 대한 형식적 심사권에 기하여 일정한 흠이 있는 등기신청은 각하하고(부등 29조), 적법한 등기신청은 이를 접수·등기하며, 그 밖에 등기사항증명서를 발급한다(19조, 상등 15조). 등기관의 결정 또는 처분에 대하여 이의가 있는 자는 그 결정 또는 처분을 한 등기관이 속한 지방법원에 이의를 신청할 수 있다(부등 100조, 상등 82조).

(3) 공 탁

법령에 따라 행하는 공탁사무는 지방법원장 또는 지방법원지원장이 소속 법원서기관 또는 법원사무관 중에서 지정하는 자가 처리한다. 다만 시·군법원의 경우에는 지방법원장 또는 지방법원지원장이 소속 법원주사 또는 법원주사보 중에서 지정하는 자가 이를 처리할 수 있다(공탁법 2조 1항). 공탁관은 접수된 공탁서를 조사하여 공탁의 수리를 결정하고(공탁규 25조, 26조), 공탁통지서를 발송하며(29조), 공탁물의 출급 및 회수를 인가한다(39조). 이해관계인은 공탁관의 처분에 대하여 불복하는 경우 그 관할 지방법원에 이의신청을 할 수 있다(공탁법 12조).

(4) 가족관계등록

가족관계의 발생 및 변동사항에 관한 등록과 그 증명에 관한 사무(이하 ‘등록사무’라 한다)는 대법원이 관장한다(가족관계등록법 2조). 다만 대법원장은 등록사무의 처리에 관한 권한을 시·읍·면의 장에게 위임하고, 등록사무의 감독에 관한 권한을 시·읍·면의 사무소 소재지를 관할하는 가정법원장에게 위임하며, 가정법원지원장은 가정법원장의 명을 받아 그 관할 구역 내의 등록사무를 감독한다(3조).

시·읍·면의 장은 등록부에 기록할 수 없는 등록사건을 제외하고는 대법원규칙으로 정하는 바에 따라 등록부에 기록을 마친 신고서류 등을 관할 법원에 송부하여야 하고(가족관계등록법 114조), 법원은 위 신고서류 등을 송부받은 때에는 지체 없이 등록부의 기록사항과 대조하고 조사하여 그 신고서류 등에 위법·부당한 사실이 발견된 경우에는 시정지시 등 필요한 처분을 명할 수 있다(115조).

등록사건에 관하여 이해관계인은 시·읍·면의 장의 위법 또는 부당한 처분에 대하여 관할 가정법원에 불복의 신청을 할 수 있다(가족관계등록법 109조). 가정법원은 신청이 이유 없는 때에는 각하하고 이유 있는 때에는 시·읍·면의 장에게 상당한 처분을 명하여야 한다(111조).

(5) 집행관 및 법무사에 대한 감독 관련 사무

집행관은 소속 지방법원장이 감독하고, 지방법원 지원의 관할구역에 있는 집행관에 대하여는 지원장이 지방법원장의 명을 받아 감독한다(집행관법 7조 1항, 2항). 지방법원장은 소속 판사 중에서 집행관의 감독에 관한 사무를 직접 담당할 한 사람 또는 여러 사람의 감독관을 지정하여야 하고, 소속 직원 중에서 감독관을 보좌할 사람을 지정할 수 있다(3항). 이와 같이 지방법원장에 의하여 감독관의 보좌역으로 지정된 법원공무원은 감독관이 행하는 감독 사무(집행관의 기록·장부 등에 대한 조사, 현장에서의 직무집행 감찰 등)를 보조하게 된다. 또한 지방법원장은 지방법원의 지원 소재지에 집행관이 없는 경우에는 관할구역의 집행관에게 지원 소재지에 출장소의 설치를 명하거나 지방법원 및 지원의 법원서기관 등으로 하여금 집행관의 직무를 대행하게 할 수 있다(11조 1항).

법무사는 소속 지방법무사회·대한법무사협회 및 그 사무소의 소재지를 관할하는 지방법원장의 감독을 받는다(법무사법 32조 1항). 지방법원장은 감독상 필요하다고 인정하면 법무사의 회계에 관한 장부 및 사건부와 그 밖에 필요한 서류를 제출하도록 명하거나 소속 공무원에게 검열하게 할 수 있다(2항).

제8절 사무의 분담 및 인계·인수

1. 사무분담

가. 의 의

하나의 법원 안에는 합의제 재판기관과 단독제 재판기관 등 여러 개의 재판부와 국, 과가 있는 것이 보통이다. 여기에서 재판기관 사이에 내부적으로 사무의 분장을 정하여야 한다는 문제가 있는데, 이를 법원 내부의 사무분담

이라고 한다.

나. 법관 등의 사무분담

(1) 사무분담의 확정

각급법원 및 지원의 재판사무 등에 관한 사무분담은 해당법원의 장이 정한다(재판사무규 4조 1항). 다만 판사회의가 설치된 법원에서는 판사회의에서 사무분담의 기본원칙을 심의하도록 되어 있다(판사회의규 5조 1항). 이러한 사무분담의 원칙을 정하기 위하여 ‘법관 등의 사무분담 및 사건배당에 관한 예규’가 제정되어 있다.

한편 고등법원의 재판사무 등에 관한 사무분담사항 중 고등법원 원외재판부(법조 27조 4항의 규정에 의하여 관할구역의 지방법원 소재지에서 사무를 처리하는 고등법원의 부)에서 근무할 법관은 대법원장이 정한다(고등규 3조 1항).

각급 법원장 및 지원장은 인사로 인하여 그 법원 또는 지원에서 근무하는 법관 및 사법보좌관(이하 ‘법관 등’이라 한다)이 정하여지거나 변경되면 지체 없이 법관 등의 사무분담을 정하여야 하는데(사무분담·사건배당예규 4조 1항), 법관 등의 사무분담을 정함에 있어, 판사회의의 심의를 거치거나 법관 등의 의견을 들어 사무분담에 관한 기본원칙을 정하고, ① 재판부의 종류(합의부 및 단독판사)와 수, 명칭 및 배당순서, ② 법관 등의 배치 및 분담사무, ③ 법관 등 유고시의 대리순서, ④ 합의부 구성판사의 합의사건에 대한 주심분담 비율(재판장에 대해서는 주심사건을 분담하지 아니하게 할 수 있다), ⑤ 사건배당 사무의 위임에 관한 사항, ⑥ 재정결정부의 구성, ⑦ ‘법원당직 및 비상근무 규칙’에 따른 당직법관의 지정에 관한 사항 등을 확정하여야 한다(2항).

(2) 사무분담의 공시 및 보고

사무분담이 확정·변경되면 지체 없이 확정·변경된 사항을 소속 각 법관 등에게 통지하고, 사법부 전산망을 통하여 게시하는 등의 방법으로 이를 공시하여야 한다(사무분담·사건배당예규 7조).

각급 법원장은 변경된 법관사무분담표를 변경일부터 10일 이내에 법원행정처장(참조 인사총괄심의관)에게 제출하여야 한다(법관사무분담보고에 관한 업무처리지침).

(3) 사무분담의 기간과 변경

각급 법원장 및 지원장은 사무분담을 확정함에 있어서, 법관의 본안사건에 관한 사무분담이 ① 재판장인 법관인 경우에는 3년(다만 형사 정식재판청구사건 전담부 및 민사소액사건 재판부의 경우에는 1년), ② 재판장이 아닌 법관인 경우에는 2년, ③ 일정 기간 동안 특정 전문 분야의 재판사무를 담당하는 판사로 보임된 법관은 해당 기간 안에 변경되지 않도록 하여야 한다. 다만 분담사무의 특성, 법관 개인이나 법원·지원의 특수한 사정으로 인하여 위 기간 안에 사무분담을 변경할 필요가 있는 경우에는 예외적으로 변경할 수 있다. 주의할 점은 각급 법원장 및 지원장이 위 ①, ②, ③의 기간 안에 사무분담을 변경한 경우에는 지체 없이 대법원장에게 그 사유를 보고(지원장은 소속 법원장을 경유)하여야 한다는 점이다(사무분담·사건배당예규 4조 4항, 5항).

각급 법원장 및 지원장은 ① 재판부의 증설 또는 폐지가 있는 때, ② 일부 재판부의 사무가 과다하여 현저히 사무분담의 균형을 잃게 된 때, ③ 일부 재판부의 법관 등이 장기간에 걸쳐 사무처리를 할 수 없는 사유가 발생한 때, ④ 법관의 비위행위에 대한 논란이 발생하여 재판에 대한 신뢰가 훼손될 우려가 있을 경우, ⑤ 그 밖에 부득이한 사유가 발생한 때에는 관계되는 재판부의 의견을 들어 확정된 법관 등의 사무분담을 변경할 수 있다(사무분담·사건배당예규 6조 1항).

(4) 합의부의 경우

합의부의 주심판사의 표시는 재판장을 ‘가’, 배석판사를 판사별로 ‘나’, ‘다’ 등의 순서로 구분하여 기재한다(사무분담·사건배당예규 8조).

합의부 내에서 사건처리의 능률을 위하여 필요한 경우에는 재판장이 주심판사의 의견을 들은 다음 주심을 변경할 수 있다. 종이기록의 경우에는 사건

기록 표지의 ‘주심표시’란의 기재를 정정하고 그 일자 및 “주심변경”이란 문자를 주서(朱書)하고 재판장이 날인한 다음, 사건배당 주관자에게 그 사유를 통지하고 변경사항을 전산 입력하여야 한다(사무분담·사건배당예규 27조 1항).

(5) 단독판사의 경우

법조경력 10년 미만인 판사는 변론을 열어서 판결하는 사건에 관하여는 단독으로 재판할 수 없다(법조 42조의3 1항). 다만 대법원장은 불가피한 경우 기간을 정하여 법조경력 10년 미만의 판사가 단독으로 재판할 것을 허가할 수 있다(3항).

(6) 상주 시·군법원 판사의 경우

관할구역 안에 상주 시·군법원(법관이 상주하여 사건을 전담하는 시·군법원)을 둔 지방법원 또는 그 지원에서는 법관의 사무분담을 정함에 있어 위 시·군법원 판사로 지명된 법관에 대하여는 시·군법원 판사로서의 업무 외에 소속 지방법원 또는 그 지원의 사무를 분담시킬 수 없다. 다만 특별한 사정이 있는 경우에는 지방법원장은 법원행정처장의 허가를 받아 지방법원 또는 그 지원의 사무를 분담시킬 수 있다(사무분담·사건배당예규 5조, 시·군법원예규 4조).

다. 법원공무원의 사무분담

‘법원사무기구에 관한 규칙’은 각급 법원에 둘 국·과 및 그 분장사무를 규정하고 있다(사무기구규 4조 내지 7조). 사무처리를 주관하는 과장은 사무의 능률적 처리와 책임소재의 명확을 기하기 위하여 소관사무를 소속직원들에게 단위업무별로 분장시키되, 소속직원 사이의 업무량이 균형되게 하여야 한다(사무관리규 5조).

법원공무원이 재판의 참여사무에 종사하게 되는 때에는 특정의 재판부에 소속하게 되는데, 이 경우 법원공무원의 담당사무는 소속재판부가 처리하게 될 사무에 의하여 결정된다.

법원공무원의 배치, 유고 시의 대리순서, 당직지정에 관한 사항 등 법원공무원의 사무분담에 관한 사항 역시 법관의 사무분담과 함께 확정하고, 사무처리상 합리적인 필요성이 있는 경우 이외에는 이를 변경하지 아니하여 사무처리의 일관성과 지속성을 유지하게 함이 바람직할 것이다. 그리고 재판 참여사무에 종사하는 법원공무원의 사무분담을 변경하는 경우에는 그 소속 재판장의 의견을 참고로 할 필요가 있다.

2. 사무의 인계·인수

가. 총 설

법원공무원이 인사발령 또는 사무분장의 조정 등의 사유로 사무를 인계·인수하는 때에는 담당사무에 관한 진행상황·관계문서·자료 기타 업무와 관련되는 사항을 구체적으로 문서로 작성하여 인계·인수하여야 한다(사무관리규 6조). 해직된 법원공무원에 대하여 사무인계 또는 잔무처리상 필요한 경우에는 소속기관의 장은 15일을 한도로 계속 근무하게 할 수 있다(법원공무원규 76조).

나. 사법행정사무의 인계·인수

법관 및 법원공무원은 ① 전보·파견·전출·휴직·정직·직위해제·면직 등의 명령을 받은 때에는 지체 없이 ‘행정사무 인계요령’에 의하여 사무인계서를 작성하고, 필요한 경우에는 설명서를 첨부하여 소속기관의 장 또는 부서의 장이 지정하는 자에게 업무를 인계하여야 하며, ② 출장·휴가 등으로 인하여 장기간 근무지를 이탈하는 경우에는 소속기관의 장 또는 부서의 장이 지정하는 자에게 그 담당업무를 인계하여야 한다(근무사항내규 7조).

법원행정사무 인계에 관한 요령을 규정하는 행정예규인 ‘행정사무 인계요령’에 따르면 대법원장, 법원행정처장, 법원행정처차장, 실·국장, 심의관, 담당관, 과장, 각급 법원 및 지원의 법원장·지원장 및 시·군법원판사, 각급

법원 및 지원의 사무국장·과장, 등기소장, 법원행정처의 과장 이상 직급자는 서면으로 사무인계서를 작성하여야 하고, 인계관·인수관 외에 입회관이 서명하여야 한다(행정인계요령 2조, 4조).

따라서 판사 중에서는 사법행정사무를 맡고 있는 법원장, 지원장, 시·군 법원판사, 법원행정처 담당관 이상 직급자의 경우에만, 법원공무원 중에서는 주로 과장급 이상의 경우에만 위 행정예규에 따른 사무인계서를 작성할 의무가 발생한다. 다만 재판부 소속 판사 또는 법원사무관등의 경우에는 다음과 같은 재판사무인계서를 작성하여야 한다.

다. 재판사무의 인계

일정한 재판사무를 담당하는 법관 또는 법원사무관등이 퇴직·전보 등의 인사발령 또는 사무분담 변경 등의 사유로 재판사무를 인계·인수하여야 할 경우에 필요한 사항은 재판예규인 ‘재판사무 인계요령’에서 규정하고 있다.

민사 본안사건(소액사건 제외) 또는 형사 공판사건을 담당하는 각급 법원 재판부의 재판장 및 이러한 재판부에 참여하는 법원사무관등(이하 ‘참여사무관’이라 한다)은 담당 재판부의 관리사건 현황과 업무처리방식 등을 명시한 재판사무인계서를 작성하여야 한다(재판인계요령 2조, 3조). 따라서 민사재판 중에서, 민사소액사건·민사조정사건·민사독촉사건·민사집행사건·민사신청사건 등을 담당하는 법관이나 참여사무관은 원칙적으로 위 재판예규에 따른 재판사무인계서를 작성할 필요가 없다. 한편 재판장이나 참여사무관이 아닌 배석판사 또는 참여주무관도 재판사무인계서를 작성할 의무가 없다.

법원장, 지원장, 시·군법원판사, 과장 등 법원행정사무를 담당하고 있는 법관 또는 법원공무원이 민사 본안사건 또는 형사 공판사건의 재판장 또는 참여사무관을 겸직하고 있는 경우에는 법원행정사무의 인계에 관한 행정예규(행정사무 인계요령)의 적용을 받는 외에도 위 재판예규의 적용을 받는다(재판인계요령 2조 2항).

재판사무인계서는 인사발령일자 또는 사무분담 변경일자에 가장 근접한 날로서 작성하기에 적정한 날을 작성기준일로 하여 작성하는데, 재판사무시스템 등을 통하여 작성할 수 있다(재판인계요령 3조 2항).

재판사무인계서는 3부(소속기관 보관용 1부, 인계자용 1부, 인수자용 1부)를 작성한다(재판인계요령 3조 3항).

먼저 소속기관 보관용 재판사무인계서의 경우, 재판장 또는 참여사무관이 이를 작성하여 소속 처리과(민사과 또는 형사과 등)에 제출하는데, 이 경우 참여사무관은 소속 재판장의 확인을 받아 제출한다. 이를 제출받은 처리과는 제출받은 재판사무인계서에 대하여 법원장·지원장(재판장의 경우) 또는 사무국장·사무과장(참여사무관의 경우)의 결재를 받은 다음 법원사무관리규칙, ‘법원사무관리규칙 시행내규’의 규정에 따라 보관하는데, 보존기간은 5년이다(재판인계요령 3조 4항).

다음으로 인수자용 재판사무인계서의 경우, 재판장용 재판사무인계서는 사건메모를 첨부하여, 참여사무관용 재판사무인계서는 사건진행카드[전산양식 A1175] 또는 기일부 등을 첨부하여 후임자에게 적절한 방법으로 전달한다(재판인계요령 3조 5항).

재판사무인계서의 양식은 ① 민사 본안사건을 담당하는 재판장용[전산양식 A2920], ② 민사 본안사건을 담당하는 참여사무관용[전산양식 A2921], ③ 형사 공판사건을 담당하는 재판장용[전산양식 B1400], ④ 형사 공판사건을 담당하는 참여사무관용[전산양식 B1401]으로 구분하여 마련되어 있다.

제3장

관 할

-
- 제1절 총 설 40
 - 제2절 직분관할 42
 - 제3절 사물관할 45
 - 제4절 시·군법원의 관할 52
 - 제5절 토지관할 53
 - 제6절 지정(재정)관할 63
 - 제7절 합의관할 64
 - 제8절 변론관할 65
 - 제9절 관할권의 조사 65
 - 제10절 소송의 이송 67

제1절 총 설

1. 관할의 의의

‘관할’이란 같거나 다른 종류의 여러 법원 사이에서 재판권 행사의 분장을 정해놓은 것을 말한다. 각 법원의 입장에서 본다면 특정 사건에 관하여 재판권을 행사할 수 있는가의 문제이기 때문에 관할권의 존재는 사건 등을 접수 처리함에 있어서 전제가 되는 요건이라 할 수 있다.

법원의 관할에 관한 사항에 대하여는 직권으로 증거조사를 할 수 있고(민소 32조), 전속관할을 위반하여 행하여진 판결은 상고의 대상이 되므로(424조 1항 3호), 접수사무를 담당하는 법원사무관등은 제출된 사건서류를 접수함에 있어서 그 법원에 관할권이 있는지 여부를 주의 깊게 검토하여야 한다.

관할은 재판권을 전제로 하지만 재판권과 구별된다. 재판권은 법원이 국가주권으로서의 사법권을 행사할 수 있는가의 문제임에 비하여, 관할은 이미 존재하는 재판권을 어느 법원에서 구체적으로 행사할 것인가의 문제이기 때문이다. 그러므로 재판권이 없는 사건은 부적법하므로 각하하여야 하지만 관할이 없는 사건은 원칙적으로 관할이 있는 법원으로 이송하여야 한다.

또한 관할은 조직법적 의미의 법원 간의 재판권의 분배에 관한 문제라는 점에서 같은 법원 내에서 특정 사건에 관하여 권한 있는 법관을 정하는 사무분담 또는 사건배당의 문제와는 그 성질을 달리하는 것이다.

2. 관할의 종류

가. 법정관할·지정(재정)관할·합의관할·변론관할

관할의 결정 근거를 기준으로 한 분류이다.

① ‘법정관할’은 법률에 의하여 직접 정하여진 관할인데, 여기에는 직분관할·사물관할·토지관할이 있다.

② ‘지정(재정)관할’이란 관할이 불분명한 경우에 관계법원의 바로 위의 상급법원의 결정에 의하여 정해지는 관할을 말한다.

③ ‘합의관할’이란 당사자의 합의에 의하여 생기게 되는 관할을 말한다.

④ ‘변론관할’이란 원고가 관할권 없는 법원에 제소하였는데, 피고가 이의 없이 본안에 대하여 변론하거나 변론준비기일에서 진술함으로써 생기는 관할을 말한다.

나. 전속관할과 임의관할

관할의 성질, 효력의 강도에 의하여 관할의 종류를 구분하여 보면, 전속관할과 임의관할로 나눌 수 있다.

(1) ‘전속관할’이란 관할을 법으로 정함에 있어 재판의 적정·공정 등 고도의 공익적 요구에 의하여 특정 법원만이 배타적으로 관할을 가지게 하는 경우를 말한다. 심급관할 등의 직분관할은 원칙적으로 전속관할이지만, 심급관할에서 비약적 상고가 인정되는 범위에서는 임의관할이 된다(민소 422조, 390조 1항 단서, 433조).

소액사건 실무와 관련하여 주로 주의하여야 할 점은, 할부거래, 특수판매(방문판매·전화권유판매·다단계판매·후원방문판매·계속거래·사업권유거래)업자와의 거래, 통신판매업자와의 거래에 관련된 소, 방문판매 및 유선·무선·화상통신·컴퓨터 등 정보통신기술을 활용한 비대면 방식을 통한 금융상품 계약과 관련된 소는 소비자의 주소를 관할하는 지방법원의 전속관할로 한다는 것이다(할부거래법 44조, 방문판매법 53조, 전자상거래법 36조, 금융소비자보호법 66조의2).

또한 도산절차상 부인의 소와 부인의 청구사건은 도산사건 계속법원의 관할에 전속하므로(채무자회생 105조 3항, 396조 3항, 584조 1항), 채권자가 제기한 채권자취소소송이 도산절차 개시로 중단된 후 관리인 등 또는 상대방이 수계한 경우(113조 1항, 2항, 59조 2항, 406조, 584조), 채권자취소소송이

계속 중인 법원이 도산사건 계속법원이 아니라면 그 법원은 관할법원인 도산사건 계속법원으로 사건을 이송하여야 한다(대법원 2018. 6. 15. 선고 2017다265129 판결).

전속관할에 대하여는 관련재판적에 관한 규정이 적용되지 아니하고, 변론관할이 성립될 여지도 없으며, 합의관할에 관한 규정이 적용되지 아니하므로(민소 31조, 25조, 29조, 30조) 이에 위반되는 관할합의의 약정 내지 약관은 무효이다.

(2) ‘임의관할’이란 주로 당사자 사이의 편의와 공평을 위한 사익적 견지에서 정하여진 것으로서, 당사자 사이의 합의나 상대방의 변론에 의하여 법정관할과 다른 관할을 발생시킬 수 있는 것을 말한다. 토지관할·사물관할은 원칙적으로 임의관할이고, 법률에 특별한 규정이 있는 경우에 한하여 전속관할이 된다.

현행법상 전속관할인 토지관할이 규정된 경우는 재심의 소(민소 453조 1항), 독촉절차(463조), 강제집행사건(민집 21조), 회사관계사건(상법 184조 내지 186조, 376조 2항, 380조), 도산사건(채무자회생 3조) 등이 있다.

제2절 직분관할

1. 의 의

‘직분관할’이란 재판권의 여러 작용을 어느 법원의 역할로 분담시킬 것인가를 정한 것을 말한다. 동일한 사건이라고 하더라도 판결절차·강제집행절차·보전처분절차와 같이 서로 다른 성질의 재판권이 발동될 수 있으며, 같은 재판절차 가운데서도 제1심·항소심·상고심에서의 재판작용이 다르므로 이를 각 적당한 법원에 배분하여 사건에 대한 법원의 기본적 역할을 정하는 것이 법원의 체제를 갖추는 데 유리하다. 직분관할은 이러한 이유에서 인정

된 것으로서 공익성이 매우 강하므로 원칙적으로 전속관할이다.

2. 수소법원

‘수소법원’은 특정사건이 계속되고 있거나, 과거에 계속되었거나, 장래 계속될 판결법원을 말한다. 소를 제기한 뒤의 증거보전절차(민소 375조, 376조), 가압류·가처분절차(민집 278조, 303조), 작위·부작위를 목적으로 하는 청구의 집행(260조, 261조)도 수소법원의 직분이 된다. 예를 들어 담보취소 신청사건은 담보제공결정을 한 법원 또는 그 기록을 보관하고 있는 법원이 관할하도록 되어 있는데(민소 125조, 민소규 23조), 이는 수소법원의 직분관할에 해당하여 성질상 전속관할에 속한다. 따라서 지방법원 합의부가 한 담보제공결정에 대한 담보취소결정을 지방법원 단독판사가 할 수 없다(대법원 2011. 6. 30. 자 2010마1001 결정). 소송비용액 확정결정(민소 110조)도 수소법원의 직분관할로서 전속관할이다(대법원 2008. 6. 23. 자 2007마634 결정). 확정판결에 대한 청구이의의 소(민집 44조 1항), 집행문부여에 대한 이의의 소(45조)는 수소법원의 직분관할로서 전속관할이므로 토지관할뿐만 아니라 사물관할도 전속관할이다(대법원 2017. 4. 7. 선고 2013다80627 판결). 따라서 1심법원인 지방법원 합의부의 항소심인 고등법원이 한 판결을 대상으로 한 청구이의의 소는 그 사건의 제1심법원인 지방법원 합의부의 전속관할에 속하고(대법원 2024. 7. 11. 자 2024그613 결정), 수소법원인 지방법원 합의부가 한 조정을 대상으로 한 집행문부여에 대한 이의의 소는 이를 처리한 지방법원 합의부의 전속관할에 속한다(대법원 2022. 12. 15. 자 2022그768 결정). 청구이의의 소 및 집행문부여에 대한 이의의 소에 부수한 강제집행정지(46조 2항)도 수소법원의 직분관할로서 성질상 전속관할에 해당한다(대법원 2022. 12. 15. 자 2022그768 결정).

3. 집행법원

‘집행법원’이란 강제집행을 실시할 수 있는 권한을 가진 법원(민집 3조)을 말한다. 민사소송은 크게 판결절차와 강제집행절차로 구분되는데, 판결절차는 수소법원의, 강제집행절차는 집행법원의 직분에 속하는 것이다. 집행법원은 채권이나 부동산에 대하여 스스로 집행처분을 할 수 있고, 그 밖에도 집행관의 강제집행실시를 감독하며(3조, 16조), 급박한 경우에는 집행정지명령을 할 권한이 있다(46조 4항, 48조 3항). 집행법원은 원칙적으로 지방법원 단독판사이다(3조, 법조 7조 4항).

4. 심급관할

‘심급관할’은 현행 민사소송제도가 상소제도를 취하는 관계상 나타나는 것으로, 하급법원의 재판에 대하여 불복을 신청한 경우에 심판할 상급법원을 정하는 관할을 말하며, 법원 간의 심판의 순서, 상하관계를 정하는 것으로서 직분관할의 성격을 갖는다. 민사소송법은 불복수단인 상소로서 제1심 재판에 대한 항소·항고 및 제2심 재판에 대한 상고·재항고의 2단계를 인정하여 이른바 3심제도를 채용하고 있다.

지방법원 합의부의 제1심 재판에 대한 항소·항고의 경우에는 고등법원이, 지방법원 단독판사의 제1심 재판에 대한 항소·항고의 경우에는 지방법원 본원 합의부 및 춘천지방법원 강릉지원 합의부가 관할한다(법조 28조, 32조 2항). 다만 아래에서 보는 바와 같이 소송목적의 값이 2억 원을 초과한 단독사건이어서 부장판사가 심판하는 사건(이른바 고액단독사건)에 대한 지방법원 단독판사의 제1심 판결·결정·명령에 대한 항소 또는 항고사건은 고등법원이 심판한다(사물관할규 4조 1항 1호). 소제기 당시 또는 청구취지 확장 당시 소송목적의 값이 2억 원을 초과하였다가 제1심 소송 과정에서 청구취지 감축, 일부 취하·각하에 의하여 소송목적의 값이 2억 원 이하가 되더라도 그 항소심은 고등법원이 관할한다(대법원 2025. 6. 12. 선고 2025다209952 판결).

지방법원 합의부가 지방법원 단독판사의 판결에 대한 항소사건을 제2심(항소심)으로 심판하는 도중에 지방법원 합의부의 관할에 속하는 소송이 새로 추가되거나 그러한 소송으로 청구가 변경되었다고 하더라도 심급관할은 제1심 법원의 존재에 의하여 결정되는 전속관할이어서 이미 정하여진 항소심의 관할에는 영향이 없는 것이므로, 추가되거나 변경된 청구에 대하여도 그대로 심판할 수 있다(대법원 1992. 5. 12. 선고 92다2066 판결). 따라서 지방법원 합의부가 지방법원 단독판사의 판결에 대한 항소사건을 제2심으로 심판하는 도중에 지방법원 합의부의 관할에 속하는 반소가 제기되었다고 하더라도 이미 정하여진 항소심의 관할에는 영향이 없다.

민사소송법 24조 2항 및 3항에 따른 특허권등의 지식재산권에 관한 소의 항소사건은 특허법원의 전속관할이다(법조 28조의4 2호). 따라서 특허권등의 지식재산권 침해로 인한 손해배상청구 사건의 제1심을 지방법원 단독판사가 심판한 경우에도 그 항소사건은 특허법원의 전속관할에 속한다(대법원 2023. 12. 28. 선고 2023다277260 판결).

제3절 사물관할

1. 총 설

법원조직법은 지방법원 및 그 지원의 심판권을 원칙적으로 단독판사가 행사하도록 하면서, 예외적으로 32조 1항 각 호 소정의 사건에 대하여는 합의부가 심판하도록 규정하고 있다(법조 7조 4항, 5항, 32조 1항). 이와 같이 지방법원 단독판사와 합의부 사이에서 제1심 소송사건의 분담을 정한 것을 사물관할이라 한다. 따라서 같은 지방법원 안이라도 합의부와 단독판사 사이의 재판권 분담은 사건배당의 문제가 아니라 관할의 문제가 되는 것이다.

2. 합의부 심판사건

지방법원 및 그 지원의 합의부는 다음 사건을 제1심으로 심판한다(법조 32조 1항, 사물관할규 2조).

가. 소송목적의 값이 5억 원을 초과하는 민사사건

소송목적의 값이 큰 사건은 처리에 신중을 기한다는 의미에서 원칙적으로 합의부의 심판사항으로 정한 것이다. 소송목적의 값은 소로 주장하는 이익을 기준으로 계산하여 정한다(민소 26조 1항). 소송목적의 값 산정에 관한 자세한 내용은 제6장(접수사무) 제3절 참조.

하나의 소로 여러 개의 청구를 하는 경우에는 그 여러 청구의 값을 모두 합하여 소송목적의 값을 정하므로(27조 1항), 각각의 청구가 단독판사의 심판사건에 속한다 하더라도 그 합산 가액이 5억 원을 초과하면 합의부의 심판사건이 된다.

다만 소송목적의 값이 5억 원을 초과하는 사건이라도 다음에 해당하는 사건은 합의부 심판사건에서 제외된다(사물관할규 2조 단서).

① 수표금·약속어음금 청구사건

② 금융기관 등이 원고인 대여금·구상금·보증금 청구사건

은행·농업협동조합·수산업협동조합·축산업협동조합·산림조합·신용협동조합·신용보증기금·기술신용보증기금·지역신용보증재단·새마을금고·상호저축은행·종합금융회사·시설대여회사·보험회사·신탁회사·증권회사·신용카드회사·할부금융회사 또는 신기술사업금융회사가 원고인 경우가 이에 해당한다.

③ 자동차손해배상 보장법에서 정한 자동차·원동기장치자전거·철도차량의 운행 및 근로자의 업무상 재해로 인한 손해배상 청구사건과 이에 관한 채무부존재확인사건

④ 단독판사가 심판할 것으로 합의부가 결정한 사건

나. 재산권상의 소로서 그 소송목적의 값을 계산할 수 없는 것과 비재산권을 목적으로 하는 소

이 경우 소송목적의 값은 5,000만 원으로 하지만(다만 해고무효확인 소를 제외한 회사 등 관계소송, 소비자기본법 및 개인정보 보호법에 따른 금지·중지청구에 관한 소송, 특허소송, 무체재산권에 관한 소송의 소송목적의 값은 1억 원. 인지 2조 4항, 인지규 18조의2), 이는 납부할 인지액 산정의 기준을 정한 것일 뿐이고, 실제로 있어서는 당사자 사이에 중대한 이해관계가 걸려 있거나 복잡한 법률문제가 개입된 사건이 많아 처리에 신중을 기할 필요가 있으므로 합의부의 심판사항으로 정한 것이다.

다. 지방법원판사에 대한 제척·기피 사건

라. 법률에 의하여 지방법원 합의부의 권한에 속하는 사건

이에 해당하는 것으로는 소송물이 단독판사의 관할에 속하지 아니하는 제3자이의의 소(민집 48조 2항), 비송사건절차법에서 특히 지방법원 합의부의 관할로 규정한 사건(비송 33조 1항, 34조 1항, 72조 1항, 109조) 등이 있다.

마. 합의부에서 심판할 것으로 합의부가 결정한 사건

(1) 총 설

합의부 심판범위에서 제외되는 사건이라도 합의부에서 심판할 것으로 합의부(재정결정부)가 결정한 사건은 합의사건이 된다(법조 32조 1항 1호).

따라서 각급 지방법원 및 그 지원에서 사무분담을 정할 때에는 재정결정부를 반드시 구성하여야 한다. 재정결정부의 구성방법은 기존의 합의부 중 특정부로 하여금 이를 겸하도록 하거나 부장판사 중에서 1명, 단독판사 또는 배석판사 중에서 2명(예컨대 민사단독판사 1명, 형사단독판사 1명 등) 등으로 새로이 재정결정부를 구성하되, 각 법원 및 지원의 실정에 맞게 적절히

구성한다.

재정합의·단독사건의 기준과 그 처리절차에 관하여는 ‘법관 등의 사무분담 및 사건배당에 관한 예규’에서 자세히 규정하고 있다.

(2) 재정합의 대상사건

제1심 단독사건 중에서 ① 선례나 판례가 없는 사건 또는 선례나 판례가 서로 엇갈리는 사건, ② 사실관계나 쟁점이 복잡한 사건, ③ 사회에 미치는 영향이 중대한 사건, ④ 동일 유형의 사건이 여러 재판부에 흩어져 통일적이고 시범적인 처리가 필요한 사건, ⑤ 전문지식이 필요한 사건, ⑥ 그 밖에 사건의 성격상 합의체로 심판하는 것이 적절한 사건에 대하여는 재정합의결정을 받을 수 있다(사무분담·사건배당예규 12조 1항). 소송목적의 값이 2억 원을 초과하는 민사사건(이른바 고액단독사건)에 대해 당사자의 합의로 제1회 변론기일 전에 합의부에서 심판받기를 원하는 신청이 있는 사건도 재정합의 대상사건이다(13조 4항 3호).

소액사건심판법에 따라 처리되는 사건은 고유의 사물관할이 있는 것이 아니고 제1심 단독사건 중에서 소송목적의 값에 따라 특례로 처리하는 것뿐이므로(대법원 1974. 7. 23. 자 74마71 결정), 소액사건 중에서도 위와 같은 요건에 해당하면 당연히 재정합의결정을 받을 수 있다. 특히 소액사건에 대하여 재정합의결정을 하여 합의부에서 심판을 하면 제2심판결을 고등법원에서 받게 되어 소액사건의 상고이유제한규정(소액 3조)을 적용받지 아니할 수 있으므로, 하급심판결이 서로 엇갈리는 소액사건으로서 대법원판례의 형성이 요구되는 예외적인 경우에는 재정합의결정의 활용이 권장된다.

(3) 재정합의결정절차(사무분담·사건배당예규 12조, 13조)

사건배당 주관자(원칙적으로 각급 법원장 및 지원장)는 재정합의 대상사건에 대하여는 사건배당에 앞서 기록회부서[전산양식 A1100]를 첨부하여 기록을 재정결정부에 회부한다. 기록을 회부받은 재정결정부는 재정합의사건으로 처리할 필요가 있다고 인정한 때에는 지체 없이 재정합의결정[전산양식 A1102]

을 하고, 그 결정을 기록에 첨부하여 사건배당 주관자에게 제출한다. 재정합의결정이 있는 때에는 종전 사건에 관하여 재정결정의 일자와 결과를 입력하고, 사건접수건수 및 처리건수를 산정함에 있어 이를 제외하며, 재정결정 일자를 기준으로 하여 새로운 합의사건으로 접수·배당한다.

한편 사건을 이미 배당받은 단독판사도 배당된 단독사건이 재정합의 대상 사건에 해당한다고 판단한 때에는 언제든지 기록회부서[전산양식 A1101]를 첨부하여 재정결정부에 기록을 회부할 수 있다(사무분담·사건배당예규 13조 4항 본문). 다만 소송목적의 값이 2억 원을 초과하는 민사사건(이른바 고액단독사건)에 대해 당사자의 합의로 제1회 변론기일 전에 합의부에서 심판받기를 원하는 신청이 있는 경우에는 지체 없이 재정결정부에 기록을 회부하여야 한다(4항 3호). 재정결정부에서 재정합의결정이 있는 때에는 종전 사건은 재정결정일자와 종국결과(‘재정합의’)를 입력하여 종결처리하고, 재정결정일자를 기준으로 하여 새로운 합의사건으로 접수·배당하고 그 기록을 새로 배당된 담당 재판부로 송부한다. 종이기록의 경우 사건기록표지는 새로 작성하지 아니하고 재정결정 전의 기록표지 중 사건번호와 ‘담임’란을 한 줄로 그어 말소한 다음 각 그 여백에 새로운 사건번호와 담임을 기재하고 ‘담임’란 하단부분에 “재정합의”라고 주서(朱書)한다.

재정결정부에서 재정합의사건으로 처리할 필요가 없다고 인정한 때에는 지체 없이 기록회부서의 하단에 “불결정”이라고 새겨진 고무인을 찍고 재정결정부 구성원이 기명날인하여[전산양식 A1104] 기록을 반환한다.

한편 합의부는 부의 구성원인 단독판사에게 배당된 단독사건 중 재정합의 대상사건에 대하여 언제든지 재정합의결정을 하고 그 합의부가 이를 심판할 수 있다. 이 경우 그 합의부의 구성원 중 주심판사를 정하고, 그 합의부의 구성원이 기명날인한 재정합의결정[전산양식 A1103]을 기록에 첨부하여 사건배당 주관자에게 제출한다. 이 경우에도 종전 사건은 재정결정일자와 종국결과(‘재정합의’)를 입력하여 종결시키고, 재정결정일자를 기준으로 새로운

합의사건으로 처리한다.

3. 단독판사의 심판사건

가. 합의부 심판사건 이외의 사건

우리 법제상 제1심법원으로서 지방법원 및 그 지원의 심판권은 단독판사가 행사함을 원칙으로 하고 있으므로(법조 7조 4항), 법률이 단순히 지방법원의 관할에 속한다고 규정한 경우는 모두 단독판사가 심판하게 된다. 따라서 앞에서 열거한 합의부 심판사건 이외의 모든 사건은 단독판사가 심판하게 된다.

‘법관 등의 사무분담 및 사건배당에 관한 예규’ 개정으로 인하여 2022. 2. 4.부터는 지방법원 및 그 지원의 단독사건 중에서 소송목적의 값이 소제기 당시 2억 원을 초과한 민사소송사건(사물관할규 2조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사건은 제외)이나 그러한 사건을 본안으로 하는 민사신청사건 및 이에 부수하는 신청사건(가압류, 다툼의 대상에 관한 가치분 신청사건 및 이에 부수하는 신청사건은 제외)은 부장판사가 심판하게 되었다(사무분담·사건배당예규 3조 4항). 이를 이른바 ‘고액단독사건’이라 한다. 다만 부장판사가 아닌 단독판사에게 배당된 사건이 청구취지 확장(변론의 병합 포함), 반소, 독립당사자참가 등으로 소송목적의 값 등이 2억 원을 초과하게 된 경우에는 위 규정에도 불구하고 부장판사가 아닌 단독판사가 계속하여 심판한다(7항).

소송사건 이외에 단독판사가 심판하는 사건으로는 독촉사건(민소 463조), 증거보전사건(375조), 제소전화해사건(385조), 공시최고사건(476조), 강제집행사건(민집 3조), 과태료사건(비송 247조) 등이 있다.

나. 재정단독사건

소송목적의 값이 5억 원을 초과하는 민사사건이라도 단독판사가 심판할 것으로 합의부가 결정한 사건은 단독사건이 된다(사물관할규 2조 4호).

사건배당 주관자는 제1심 합의사건 중 사안이 단순하고 정형적인 사건을 사건배당에 앞서 재정결정부에 회부할 수 있고, 재정단독결정이 있는 때에는 재정결정일자를 기준으로 하여 새로운 단독사건으로 접수·배당한다(사무분담·사건배당예규 12조 2항, 4항).

한편 합의부는 부에 배당된 제1심 합의사건 중 사안이 단순하고 정형적인 사건에 대하여는 직접 해당 합의부의 구성원 중 담당판사를 지정하고, 합의부의 구성원이 기명날인한 재정단독결정[전산양식 A1103]을 기록에 첨부하여 사건배당 주관자에게 제출할 수 있다(사무분담·사건배당예규 13조 1항 1호). 담당판사를 해당 합의부의 구성원 중에서 지정하지 않기 위해서는 기록 회부서[전산양식 A1101]와 함께 재정결정부에 기록을 회부하여 재정단독결정[전산양식 A1102]을 받아야 한다(1항 2호, 5항).

재정단독결정의 절차와 재정단독결정이 있는 때의 업무처리절차는 사건배당 확정 전인 경우와 사건배당 확정 후인 경우에 따라 달라지는데, 이에 관하여는 재정합의결정절차의 경우를 참조하면 된다.

4. 사물관할과 재배당

같은 지방법원(지원) 안에서 착오에 의하여 합의사건이 단독사건으로, 또는 단독사건이 합의사건으로 배당된 때에는 재배당을 실시한다(사무분담·사건배당예규 26조 1항, 14조 8호). 이러한 재배당이 완료된 경우에는 사건배당부[전산양식 A1121, A1122] ‘비고’란에 재배당의 취지를 기재하고, 종전 사건은 종국결과를 ‘재배당’으로 입력하여 종결처리하며, 그 기록을 재배당된 담당재판부로 송부하되, 기록 표지의 완결공람은 하지 않는다. 기록을 송부받은 재판부에서는 송부받은 날짜를 기준으로 신건으로 접수하여 새로운 사건번호를 부여한다. 종이기록의 경우 기록표지를 새로 작성하고 ‘담임’란 하단부분에 “재배당”이라고 주서(朱書)한다(26조 4항).

한편 사건배당 확정 후에 재정합의결정 또는 재정단독결정이 있는 때에도

재배당을 실시한다(사무분담·사건배당예규 26조 1항, 14조 2호).

제4절 시·군법원의 관할

1. 시·군법원의 민사소송 관할

대법원장은 지방법원 또는 그 지원 소속 판사 중에서 그 관할구역에 있는 시·군법원의 판사를 지명하여 시·군법원의 관할사건을 심판하게 한다(법조 33조 1항).

법원조직법 34조 1항은 시·군법원의 민사소송 관할사건으로서, ① 소액 사건심판법의 적용을 받는 민사사건(소송목적의 값이 3,000만 원을 초과하지 아니하는 금전 기타 대체물이나 유가증권의 일정한 수량의 지급을 목적으로 하는 제1심 민사사건. 소액규 1조의2), ② 화해·독촉 및 조정에 관한 사건을 규정하고 있다.

나아가 시·군법원은 ① 소액사건심판법의 적용대상인 사건을 본안으로 하는 보전처분사건(이의·취소 사건 포함), ② 소액사건 범위 내의 판결·화해·조정·지급명령에 기초한 집행문부여의 소, 청구에 관한 이의의 소, 집행문 부여에 대한 이의의 소도 관할하는 것으로 해석된다(민집 22조의 반대해석).

이러한 시·군법원 관할의 성격에 대하여는 명문의 규정은 없으나, 법원조직법의 규정취지에 비추어 볼 때 시·군법원이 위와 같이 법에서 규정하고 있는 관할에 속하지 아니하는 사건(예컨대 건물인도사건이나 소송목적의 값이 3,000만 원을 초과하는 금전청구사건 등)을 처리하는 경우에는 전속관할의 일종인 직분관할 위반이라고 볼 것이다.

한편 지방법원(지원)에서 시·군법원 사건을 처리하는 경우에는 토지관할 위반이라고 해석할 수 있을 것이다. 따라서 시·군법원의 관할에 속하는 소액사건을 지방법원 또는 지원에 제기한 경우에는 토지관할 위반이므로, 접

수담당자로서는 이 점에 유의하여 당사자로 하여금 관할법원에 소를 제기하도록 유도하여야 할 것이다.

2. 시·군법원의 관할구역

각급 법원의 설치와 관할구역에 관한 법률에서 시·군법원의 설치와 그 관할구역을 정하고 있는데, 그 관할구역은 위 법률 [별표 7]과 같다.

제3장

관
할

제5절 토지관할

1. 의 의

가. 법원의 관할구역

각급 법원의 설치와 관할구역에 관한 법률은 전국적으로 설치된 법원의 권한행사 구역으로서 각 법원의 관할구역을 정하고 있다. 각 고등법원 및 지방법원(지원)의 관할구역은 다음과 같다(법원설치법 [별표 3]).

다만 인천고등법원과 인천지방법원 북부지원은 2028. 3. 1.에, 세종지방법원은 2031. 3. 1.에 설치된다. 그 전까지는 인천고등법원 관할에 속할 사건은 서울고등법원, 인천지방법원 북부지원 관할에 속할 사건은 인천지방법원, 세종지방법원 관할에 속할 사건은 대전지방법원의 관할이다.

[고등법원 및 지방법원(지원)의 관할구역]

고등 법원	지방법원	지원	관할구역
서울	서울중앙		서울특별시 종로구·중구·강남구·서초구·관악구·동작구
	서울동부		서울특별시 성동구·광진구·강동구·송파구
	서울남부		서울특별시 영등포구·강서구·양천구·구로구·금천구
	서울북부		서울특별시 동대문구·종로구·성북구·도봉구·강북구·노원구
	서울서부		서울특별시 서대문구·마포구·은평구·용산구
	의정부		의정부시·동두천시·양주시·연천군·포천시, 강원도 철원군. 다만 소년보호 사건은 앞의 시·군 외에 고양시·파주시·남양주시·구리시·가평군
		고 양	고양시·파주시
		남양주	남양주시·구리시·가평군
	춘천		춘천시·화천군·양구군·인제군·홍천군. 다만 소년보호사건은 철원군을 제외한 강원도
		강릉	강릉시·동해시·삼척시
		원주	원주시·황성군
		속초	속초시·양양군·고성군
		영월	태백시·영월군·정선군·평창군
대전	대전		대전광역시·금산군
		홍성	보령시·홍성군·예산군·서천군
		공주	공주시·청양군
		논산	논산시·계룡시·부여군
		서산	서산시·당진시·태안군
		천안	천안시·아산시
	세종		세종특별자치시
	청주		청주시·진천군·보은군·괴산군·증평군. 다만 소년보호사건은 충청북도
		충주	충주시·음성군
		제천	제천시·단양군
		영동	영동군·옥천군
대구	대구		대구광역시 중구·동구·남구·북구·수성구·영천시·경산시·칠곡군·청도군
		서부	대구광역시 서구·달서구·달성군, 성주군·고령군
		안동	안동시·영주시·봉화군
		경주	경주시
		포항	포항시·울릉군
		김천	김천시·구미시
		상주	상주시·문경시·예천군
		의성	의성군·군위군·청송군

고등 법원	지방법원	지원	관할구역
		영덕	영덕군·영양군·울진군
부산	부산		부산광역시 중구·동구·영도구·부산진구·동래구·연제구·금정구
		동부	부산광역시 해운대구·남구·수영구·기장군
		서부	부산광역시 서구·북구·사상구·사하구·강서구
	울산		울산광역시·양산시
	창원		창원시 의창구·성산구·진해구, 김해시
		마산	창원시 마산합포구·마산회원구, 함안군·의령군
		통영	통영시·거제시·고성군
		밀양	밀양시·창녕군
		거창	거창군·함양군·합천군
		진주	진주시·사천시·남해군·하동군·산청군
광주	광주		광주광역시·나주시·화순군·장성군·담양군·곡성군·영광군
		목포	목포시·무안군·산안군·함평군·영암군
		장흥	장흥군·강진군
		순천	순천시·여수시·광양시·구례군·고흥군·보성군
		해남	해남군·완도군·진도군
	전주		전주시·김제시·완주군·임실군·진안군·무주군. 다만 소년보호사건은 전북 특별자치도
		군산	군산시·익산시
		정읍	정읍시·부안군·고창군
		남원	남원시·장수군·순창군
	제주		제주시·서귀포시
수원	수원		수원시·오산시·용인시·화성시. 다만 소년보호사건은 앞의 시 외에 성남시·하남시·평택시·이천시·안산시·광명시·시흥시·안성시·광주시·안양시·과천시·의왕시·군포시·여주시·양평군
		성남	성남시·하남시·광주시
		여주	이천시·여주시·양평군
		평택	평택시·안성시
		안산	안산시·광명시·시흥시
		안양	안양시·과천시·의왕시·군포시
인천	인천		인천광역시 영종구·제물포구·미추홀구·연수구·남동구·부평구·옹진군
		북부	인천광역시 검단구·계양구·서구·강화군
		부천	부천시·김포시

나. 토지관할과 재판적

같은 종류의 직분관할에 속하는 사건들을 소재지를 달리하는 같은 종류의 법원 중 어떠한 법원에 분장시킬 것인가 하는 관할의 정함을 토지관할이라고 한다.

민사소송법은 토지관할을 결정하는 기준으로서 사건의 당사자 또는 그 권리관계의 장소적 관련지점을 뜻하는 재판적의 개념을 사용하여 이를 법원의 관할구역과 연결시키는 방식으로 제1심의 토지관할을 정하고 있다. 즉 재판적이란 어떤 사건 또는 당사자가 일정 지역을 관할하는 법원의 재판권에 복종하게 되는 근거가 되는 관계지점을 의미한다.

재판적에는 사건의 종류나 내용을 불문하고 민사소송에 관하여 일반적인 토지관할을 정하는 보통재판적과 사건의 종류나 내용에 따라 한정된 사건에 한하여 보통재판적과 경합적으로 또는 그 예외로서 인정되는 토지관할을 정하는 특별재판적이 있다. 재판적은 또한 그 관할의 표준이 되는 근거의 성격에 따라 당사자 특히 피고로 될 자와의 관계에 의하여 정하여지는 인적 재판적과 소송의 목적인 권리관계와의 관계에 의하여 정하여지는 물적 재판적으로 나눌 수 있다.

2. 보통재판적

가. 자연인

소는 피고의 보통재판적이 있는 곳의 법원이 관할한다(민소 2조). 사람의 보통재판적은 그의 주소에 따라 정한다. 다만 대한민국에 주소가 없거나 주소를 알 수 없는 경우에는 거소에 따라 정하고, 거소가 일정하지 아니하거나 거소도 알 수 없으면 마지막 주소에 따라 정한다(3조).

외국에 주재하는 대한민국의 대사, 공사와 그 가족 등 대한민국 국민으로서 외국의 재판권 행사대상에서 제외되는 사람에게 민사소송법 3조에 따른 보통재판적이 없는 경우 이들의 보통재판적은 대법원이 있는 곳으로 한다

(민소 4조).

나. 법인 등의 단체

법인, 그 밖의 사단 또는 재단의 보통재판적은 이들의 주된 사무소 또는 영업소가 있는 곳에 따라 정하고, 사무소와 영업소가 없는 경우에는 주된 업무담당자의 주소에 따라 정한다(민소 5조 1항). 외국법인 등의 경우에도 국내에 있는 사무소, 영업소 또는 업무담당자의 주소에 따라 정한다(2항).

다. 국 가

국가가 민사소송의 당사자로 되는 경우 그 보통재판적은 그 소송에서 국가를 대표하는 관청인 법무부장관의 소재지 또는 대법원이 있는 곳으로 한다(민소 6조, 국당 2조).

라. 보통재판적을 정할 수 없는 때

민사소송법 3조 내지 6조에 따라 보통재판적을 정할 수 없는 때에는 대법원이 있는 곳을 보통재판적으로 한다(민소규 6조). 외국국가 또는 국내에 주소 등을 갖지 않은 외국인이나 외국법인 및 마지막 주소를 알 수 없는 내국인을 상대로 하여 소송을 하여야 할 경우 당사자의 제소와 응소의 편의를 위하여 대법원 소재지를 보통재판적으로 한 것이다.

3. 특별재판적

가. 총 설

특별재판적은 민사소송법 7조 내지 25조에 규정되어 있는데, 이에에는 그 사건에 관하여 본래 인정되는 독립재판적과 다른 사건과 관련하여 발생하는 관련재판적이 있다. 특별재판적은 어느 것이나 앞서 본 보통재판적과 경합하는 임의관할이기 때문에 당사자는 경합되는 재판적 중 하나를 편의에 따

라 선택할 수 있다.

나. 독립재판적

(1) 근무지

사무소 또는 영업소에 계속하여 근무하는 사람에 대하여 소를 제기하는 경우에는 그 사무소 또는 영업소가 있는 곳을 관할하는 법원에 제기할 수 있다(민소 7조).

(2) 거소지 또는 의무이행지

재산권에 관한 소는 거소지 또는 의무이행지의 법원에 제기할 수 있다(민소 8조). 이는 의무를 전제로 하는 재산권상의 권리관계에 관한 소에 대하여 이행의 소이든 확인의 소이든 불문하고 인정되는 재판적이다. 의무이행지는 당사자 사이의 특약, 법률의 규정 또는 의무의 성질에 따라 정해진다. 민법은 특정물인도 이외의 채무변제는 채권자의 현주소 또는 영업소에서 하여야 한다고 규정하여(민법 467조) 이른바 지참채무의 원칙을 취하고 있으므로, 이 경우에는 통상 원고로 되는 채권자의 주소나 영업소 소재지의 법원에 제소할 수 있게 된다. 민법 467조 2항의 ‘영업에 관한 채무’는 영업과 관련성이 인정되는 채무를 의미하고, ‘현영업소’는 변제 당시를 기준으로 그 채무와 관련된 채권자의 영업소로서 주된 영업소(본점)에 한정되는 것이 아니라 그 채권의 추심 관련 업무를 실제로 담당하는 영업소까지 포함된다. 따라서 영업에 관한 채무의 이행을 구하는 소는 제소 당시 채권 추심 관련 업무를 실제로 담당하는 채권자의 영업소 소재지 법원에 제기할 수 있다(대법원 2022. 5. 3. 자 2021마6868 결정). 사해행위취소의 소에서 의무이행지는 ‘취소의 대상인 법률행위의 의무이행지’가 아니라 ‘취소로 인하여 형성되는 법률관계에서의 의무이행지’이다(대법원 2002. 5. 10. 자 2002마1156 결정).

(3) 어음·수표 지급지

어음·수표에 관한 소는 그 지급지의 법원에 제기할 수 있다(민소 9조). 어

음·수표에 관한 소란 약속어음 발행인에 대한 어음금지급청구, 배서인에 대한 상환청구 등을 말한다. 그러나 상환청구통지의 해태로 인한 손해배상청구나 이득상환청구와 같은 어음·수표법상의 권리에 관한 소는 이에 해당하지 않는다.

(4) 군사용의 청사 소재지 또는 군용 선박의 선적 소재지

군인·군무원에 대한 재산권에 관한 소는 군사용 청사가 있는 곳 또는 군용 선박의 선적이 있는 곳의 법원에 제기할 수 있다(민소 10조 2항).

(5) 재산 소재지

국내에 주소가 없거나 알 수 없는 사람에 대한 재산권에 관한 소는 청구의 목적 또는 담보의 목적이나 압류할 수 있는 피고의 재산이 있는 곳의 법원에 제기할 수 있다(민소 11조).

(6) 사무소·영업소 소재지

사무소 또는 영업소가 있는 사람에 대하여 그 사무소 또는 영업소의 업무와 관련이 있는 소를 제기하는 경우에는 그 사무소 또는 영업소가 있는 곳의 법원에 제기할 수 있다(민소 12조). 여기서 '업무와 관련이 있는 소'란 업무의 목적에 관련이 있는 한 그 본래의 업무 자체의 수행에 따른 법률관계에 관한 것뿐만 아니라 그 본래의 업무를 집행할 경우에 파생되는 모든 권리·의무에 관한 소를 포함한다(대법원 2011. 8. 16. 자 2011무67 결정). 그리고 여기서 말하는 사무소나 영업소는 반드시 주된 사무소나 영업소일 필요는 없지만 적어도 어느 정도 독립하여 업무의 전부 또는 일부가 총괄적으로 경영되는 장소이어야 한다.

(7) 선적 소재지

선박 또는 항해에 관하여 선박소유자, 그 밖의 선박이용자에 대한 소(민소 13조) 및 선원에 대한 재산권에 관한 소(10조 1항)는 선적(船籍)이 있는 곳의 법원에 제기할 수 있다. 이때 선적 소재지는 선적항, 즉 선박의 등기·등록을 관할하는 법원을 정하기 위한 기준이 되는 항구(선박법 8조, 선박등기법 4조)

가 위치한 곳을 의미하고, 선박이 물리적으로 위치하는 선박 소재지를 의미하는 것은 아니다.

(8) 선박 소재지

선박채권, 그 밖에 선박을 담보로 한 채권에 관한 소는 선박이 있는 곳의 법원에 제기할 수 있다(민소 14조).

(9) 회사, 그 밖의 사단의 보통재판적 소재지

회사, 그 밖의 사단이 사원에 대하여 제기하거나 사원이 다른 사원에 대하여 제기하는 소로서 그 소가 사원의 자격으로 말미암은 것(민소 15조 1항), 사단 또는 재단이 그 임원에 대하여 제기하는 소와 회사가 그 발기인 또는 검사인에 대하여 제기하는 소(2항), 회사, 그 밖의 사단의 채권자가 그 사원에 대하여 사원의 자격으로 말미암아 제기하는 소(16조), 회사, 그 밖의 사단, 재단, 사원 또는 사단의 채권자가 그 사원·임원·발기인 또는 검사인이었던 사람에 대하여 제기하는 소와 사원이었던 사람이 그 사원에 대하여 제기하는 소(17조)는 모두 회사, 그 밖의 사단 또는 재단의 보통재판적이 있는 곳의 법원에 제기할 수 있다.

(10) 불법행위지

불법행위에 관한 소는 그 행위지의 법원에 제기할 수 있다(민소 18조 1항). 또한 선박 또는 항공기의 충돌이나 그 밖의 사고로 인한 손해배상의 소는 그 선박 또는 항공기가 맨 처음 도착한 곳의 법원에 제기할 수 있다(2항). 여기서 ‘맨 처음 도착한 곳’이란 사고선박 또는 항공기가 외국의 육상 지점을 거치지 아니하고 처음으로 직접 도착한 국내의 지점만을 의미한다. 충돌한 두 선박이나 항공기가 각각 다른 지점에 처음으로 도착하였다면 그 두 곳의 재판적이 경합하게 된다.

(11) 해난구조지 또는 선박의 최초 도착지

해난구조에 관한 소는 구조지 또는 구조된 선박이 맨 처음 도착한 곳의 법원에 제기할 수 있다(민소 19조).

(12) 부동산 소재지

부동산에 관한 소는 부동산이 있는 곳의 법원에 제기할 수 있다(민소 20조). 여기에서의 ‘부동산에 관한 소’에는 부동산물권에 기하여 부동산을 직접의 목적으로 하는 확인·인도 등의 청구뿐만 아니라 부동산에 관한 채권관계에 기하여 부동산물권의 설정·이전, 점유의 이전, 등기의 이행 등의 급부를 구하는 소도 포함되나, 부동산의 매매대금이나 임료의 청구에 관한 소는 포함되지 않는다.

(13) 등기·등록지

등기·등록에 관한 소는 등기 또는 등록할 공공기관이 있는 곳의 법원에 제기할 수 있다(민소 21조).

(14) 피상속인의 보통재판적 소재지

상속에 관한 소 또는 유증, 그 밖의 사망으로 효력이 생기는 행위에 관한 소는 상속개시 당시의 피상속인의 보통재판적 소재지의 법원에 제기할 수 있다(민소 22조). 상속채권, 그 밖의 상속재산에 대한 부담에 관한 것으로 위 민사소송법 22조의 규정에 해당하지 아니하는 소는 상속재산의 전부 또는 일부가 위 규정의 법원관할구역 안에 있으면 그 법원에 제기할 수 있다(23조).

(15) 지식재산권 등에 관한 특별재판적

특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 품종보호권(이하 ‘특허권등’이라 한다)을 제외한 지식재산권과 국제거래에 관한 소를 제기하는 경우에는 민사소송법 2조 내지 23조의 규정에 따른 관할법원 소재지를 관할하는 고등법원 소재지의 지방법원에 제기할 수 있다. 다만 서울고등법원이 있는 곳의 지방법원은 서울중앙지방법원으로 한정한다(민소 24조 1항). 지식재산권이나 국제거래에 관한 소는 전문적이고 기술적인 요소가 강한 사건으로 법원은 그러한 사건의 특수성을 고려하여 전문재판부를 설치하고 있다. 그러나 그러한 전문재판부가 전국의 모든 법원에 설치된 것은 아니고, 현재 적어도 고등법원 단위로는 그와 함께 있는 지방법원에 전문재판부가 설치되어 있는 경

우가 많으므로 그와 같은 지방법원에 소를 제기할 수 있도록 한 것이다.

특허권등의 지식재산권에 관한 소는 민사소송법 2조부터 23조까지의 규정에 따른 관할법원 소재지를 관할하는 고등법원이 있는 곳의 지방법원의 전속 관할이다(다만 서울고등법원이 있는 곳의 지방법원은 서울중앙지방법원으로 한정한다). 그러나 이 전속관할에도 불구하고 당사자는 서울중앙지방법원에 특허권등의 지식재산권에 관한 소를 제기할 수 있다(민소 24조 2항, 3항). 특허권등의 지식재산권에 관한 소의 항소사건은 특허법원의 전속관할이다(법조 28조의4 2호). 특허권등의 지식재산권에 관한 소는 특허권등의 침해에 따른 금지 청구, 손해배상청구, 신용회복조치청구의 소를 말한다. 특허 관련 분쟁을 해결하기 위하여 당사자가 작성한 합의서에 대해, 그 합의내용을 위반하였다고 주장하면서 일방 당사자가 상대방을 상대로 제기한 위약벌 지급청구 사건도 특허권 등의 지식재산권에 관한 소에 해당하므로 그 항소사건은 특허법원의 전속관할에 속한다(대법원 2024. 10. 31. 선고 2024다228906 판결).

지식재산권과 국제거래에 관한 소에 대하여는 편의이송에 관한 특별규정이 있다(민소 36조).

다. 관련재판적

하나의 소로 여러 개의 청구를 하는 경우에는 앞에서 설명한 보통재판적 또는 특별재판적의 규정에 의하여 하나의 청구에 대한 관할권이 있는 법원에 그 소를 제기할 수 있다(민소 25조 1항). 따라서 청구의 병합에 관한 다른 요건이 충족되어 있다면(253조 등) 그중 하나의 청구에 대한 관할권이 있는 한 관할권이 없는 다른 청구에 대하여도 그 법원에 관할권이 인정된다.

또한 하나의 소로 여러 피고에 대하여 청구를 하는 이른바 주관적 병합의 경우에도 소송목적이 되는 권리나 의무가 여러 사람에게 공통되거나 사실상 또는 법률상 같은 원인으로 말미암아 여러 사람이 공동소송인으로서 당사자가 되는 경우에는 그중 1인에 관한 청구에 대하여 관할권이 있는 한 관할권

이 없는 다른 사람에 관한 청구에 대하여도 그 법원에 관할권이 인정된다(민소 25조 2항). 즉 통상공동소송은 민사소송법 65조 전문에 해당하는 경우에만 관련재판적이 인정되고, 65조 후문의 경우에는 관련재판적이 인정되지 않는다.

다만 특정한 법원의 전속관할로 정하여진 소에 대하여는 관련재판적의 규정을 적용할 수 없다(민소 31조).

민사소송의 일방 당사자가 다른 청구에 관하여 관할만을 발생시킬 목적으로 본래 제소할 의사 없는 청구를 병합한 것이 명백한 경우에는 관할선택권의 남용으로서 신의칙에 위배되어 허용될 수 없으므로, 그와 같은 경우에는 관련재판적에 관한 민사소송법 25조의 규정을 적용할 수 없다(대법원 2011. 9. 29. 자 2011마62 결정).

제6절 지정(재정)관할

관할법원이 재판권을 법률상 또는 사실상 행사할 수 없는 때 또는 법원의 관할구역이 분명하지 아니한 때에는 관계된 법원과 공통되는 바로 위의 상급법원이 그 관계된 법원 또는 당사자의 신청에 따라 결정으로 관할법원을 정하게 되는데 이를 지정관할 또는 재정관할이라고 한다(민소 28조 1항).

여기서 관할법원이 ‘재판권을 법률상 행사할 수 없는 때’란 관할법원 법관이 모두 제척·기피 또는 회피로 인하여 직무를 수행할 수 없는 경우 등을 말하고, ‘재판권을 사실상 행사할 수 없을 때’란 관할법원 법관이 모두 질병이나 천재지변 등의 사고로 직무를 수행할 수 없는 경우 등을 말한다.

소제기 후의 사건에 관하여 관할지정신청이 있는 때에는 그 신청에 대한 결정이 있을 때까지 소송절차를 정지하여야 한다. 다만 긴급한 필요가 있는 행위를 하는 경우에는 그러하지 아니하다(민소규 9조).

관할지정결정에 대하여는 불복할 수 없다(민소 28조 2항). 그러나 관할지정 신청을 기각한 결정에 대하여는 항고를 제기할 수 있다(439조).

소송이 계속된 법원 이외의 법원이 관할법원으로 지정된 경우에는 소송이 계속된 법원의 법원사무관등은 바로 그 결정정보와 소송기록을 지정된 법원으로 보내야 한다(민소규 8조 3항).

제7절 합의관할

당사자는 일정한 법률관계로 말미암은 소에 관하여 서면으로 한 합의에 의하여 제1심 관할법원을 정할 수 있다(민소 29조). 이 합의는 당사자가 법정의 임의관할과 다른 내용의 관할을 정하겠다는 소송법상의 합의이며 반드시 서면에 의하여야 한다. 합의는 계약서에 한 조항으로 정해지는 것이 보통이지만 반드시 동시에 이루어질 필요는 없다.

관할의 합의에는 특정한 법원에 대하여 관할권을 인정하고 그 밖의 다른 법원의 관할권을 배제하는 전속적 합의와 법정관할 이외의 다른 법원을 부가하는 부가적 합의가 있다. 명시적으로 전속적 또는 부가적 합의를 하였을 때에는 합의된 바에 따를 것이나, 명시적 합의가 없는 경우에는 법정 관할법원 가운데 어느 하나를 지정하였을 때에는 전속적 합의로 보고 그렇지 아니한 경우에는 부가적 합의로 봄이 상당하다. 당사자들이 법정 관할법원에 속하는 여러 관할법원 중 어느 하나의 법원을 관할법원으로 하기로 약정한 경우에, 그와 같은 약정은 그 약정이 이루어진 국가 내에서 재판이 이루어질 것을 예상하여 그 국가 내에서의 전속적 관할법원을 정하는 취지의 합이라고 해석될 수 있다(대법원 2008. 3. 13. 선고 2006다68209 판결).

관할의 합의가 있으면 그로써 관할이 변경되는 효과가 생긴다. 그러나 전속적 합의관할을 정한 경우에도 그 성질은 임의관할이므로 변론관할이 생길

여지가 있고(대법원 1963. 5. 15. 선고 63다111 판결), 또 법원으로서도 손해나 지연을 피하기 위하여 이송을 할 수도 있다는 점에서 법률상의 전속관할과는 다르다.

관할합의의 효력은 원칙적으로 제3자에게 미치지 않지만, 지명채권과 같이 그 권리관계의 내용을 당사자가 자유롭게 정할 수 있는 경우에는 그 권리관계의 특정승계인은 그와 같이 변경된 권리관계를 승계한 것이라고 할 것이므로 관할합의의 효력은 특정승계인에게도 미친다(대법원 2006. 3. 2. 자 2005마902 결정). 그러나 관할합의가 있는 후 채권양도 등의 사유로 외국적 요소가 있는 법률관계에 해당하게 된 때에는 다른 국가의 재판관할권이 성립될 수 있고, 이 경우에는 위 관할합의의 효력이 미치지 아니하게 될 수 있다(대법원 2008. 3. 13. 선고 2006다68209 판결).

다만 특정한 법원의 전속관할로 정하여진 소에는 합의관할의 규정을 적용할 수 없다(민소 31조).

제8절 변론관할

피고가 제1심 법원에서 관할위반이라고 항변하지 아니하고 본안에 대하여 변론하거나 변론준비기일에서 진술하면 그 법원은 관할권을 가진다(민소 30조). 그러나 전속관할이 정하여진 소에는 이 규정을 적용하지 아니한다(31조).

제9절 관할권의 조사

1. 직권조사사항

법원은 관할에 관한 사항에 대하여 직권으로 증거조사를 할 수 있다(민소

32조). 관할권은 법원이 사건에 관하여 재판권을 행사할 권한으로서 소의 심판에 있어서는 소송요건, 즉 청구의 당부에 관하여 본안판결을 할 수 있는 전제요건을 이루는 것이다. 따라서 법원은 우선 사건에 관하여 관할권의 유무를 확인한 후에 본안심리에 들어가야 한다. 관할권의 존부에 관하여 의문이 있는 때에는 심리 중 언제라도 직권으로 조사하여야 하고, 직권으로 증거조사도 할 수 있다.

특히 전속관할에 관하여는 법원이 관할원인의 유무를 적극적으로 조사하여야 한다. 임의관할은 당사자가 변경할 수 있는 성질의 것이므로 관할원인에 대하여 당사자 사이에 다툼이 없으면 이에 대한 증명 없이 관할을 인정하여도 무방하다.

2. 관할결정의 표준시기

법원의 관할은 소를 제기한 때를 표준으로 하여 정한다(민소 33조). ‘소를 제기한 때’란 소장을 법원에 제출한 때를 말하므로 소를 제기한 때 관할이 인정되는 한 그 후 발생한 사정변경의 영향을 받지 아니한다. 즉 제소 후에 피고의 주소지 등이 변경되거나 목적물의 훼손·멸실 등으로 소송목적의 값이 변경된 경우라도 토지관할이나 사물관할에는 아무런 변동이 없다. 관련 재판적에 의하여 소를 제기한 때에 적법하게 병합된 것이라면 관할원인으로 된 청구가 그 후 취하·각하되거나 변론의 분리가 있어 병합관계가 소멸되어도 다른 청구의 관할에 영향을 미치지 아니한다.

당사자가 청구를 변경한 경우에는 원칙적으로 신소의 제기 당시를 표준으로 관할이 변동된다고 볼 것이다. 그러므로 단독사건으로 심리하는 도중에 합의부 사건으로 청구가 확장된 경우에는 신소는 합의부의 관할이 된다. 이 경우에는 변론관할이 생길 여지가 있으므로 당사자의 의사를 확인한 후 이송 여부를 결정함이 상당하다. 그러나 이와 반대로 합의부 사건으로 심리하는 도중에 청구의 감축으로 단독사건으로 되었다고 하더라도 합의부에서 단

독판사로 이송하지는 않는다. 왜냐하면 이 경우에 합의부에서 심판받더라도 당사자에게 불리하지 않을 뿐만 아니라 소송경제에도 부합하기 때문이다.

본소가 단독사건인 경우에 피고가 반소로 합의사건에 속하는 청구를 한 때에는 원칙적으로 본소와 반소를 합의부에 이송하여야 한다. 다만 반소에 관하여 변론관할이 생기면 그러하지 아니하다(민소 269조 2항).

3. 조사의 결과

조사 결과 관할권의 존재가 인정되면 법원은 심리를 그대로 진행할 것이지만 당사자 사이에 관할권의 존재에 관하여 다툼이 있으면 중간판결이나 종국판결의 이유에서 이에 관한 판단을 한다.

조사 결과 관할권이 없는 때에는 소각하판결을 할 것이 아니라 관할권이 있는 법원으로 이송하여야 한다. 임의관할의 위반을 간과하고 본안판결을 하였을 때에는 그 흠이 치유되지만(민소 411조 본문), 전속관할 위반의 경우에는 상소심에서 다룰 수 있다(411조 단서, 424조 1항 3호). 항소심법원이 전속관할 위반을 이유로 제1심판결을 취소하는 때에는 판결로 사건을 관할법원에 이송하여야 한다(419조). 다만 전속관할 위반을 간과한 판결이라도 재심의 대상은 아니다.

제10절 소송의 이송

1. 의 의

‘소송의 이송’이란 어느 법원에 일단 계속된 소송을 그 법원의 재판에 의하여 다른 법원에 이전하는 것을 말한다.

소송의 이송 제도는 관할위반의 경우 소를 각하하기보다는 관할권이 있는 법원에 이송함으로써 다시 소를 제기할 때 들이는 시간·노력·비용을 절감

하게 하고, 소제기에 의한 시효중단·제척기간준수의 효력을 유지시켜 소송 경제에 도움이 되게 하며, 나아가 관할위반이 아닌 경우라도 소송촉진과 소송경제의 입장에서 보다 편리한 법원으로 옮겨 심판할 수 있도록 하려는 데 그 의의가 있다.

이송에는 제1심 소송의 이송 이외에 상급심에서 하는 이송(민소 419조, 436조)도 있다. 상급심에서 원심으로 환송하는 것도 넓은 의미에서는 이송이다.

2. 요 건

가. 관할위반에 따른 이송

법원은 소송의 전부 또는 일부에 대하여 관할권이 없다고 인정하는 경우에는 결정으로 이를 관할법원에 이송한다(민소 34조 1항). 이 규정은 본래 당사자가 관할권 없는 제1심법원에 소를 제기한 경우를 상정한 것이나, 제1심의 소를 고등법원이나 대법원에 제기한 경우에도 이 규정을 적용할 수 있고, 제1심법원이 항소기록을 잘못 송부한 경우 지방법원 항소부와 고등법원 사이에서도 위 규정에 의한 이송이 인정된다.

한편 당사자가 상소장을 원심법원이 아닌 상소법원에 제출하였을 경우 상소법원이 그 상소장을 원심법원에 이송할 수 있는지에 관하여는 견해의 대립이 있으나 실무는 상소장을 원심법원에 송부하고 있고, 상소기간의 준수 여부는 원심법원에 상소장이 접수된 때를 기준으로 판단한다(대법원 1981. 10. 13. 선고 81누230 판결, 대법원 2010. 12. 9. 선고 2007다42907 판결).

가정법원·행정법원에 관할권이 없는 사건이 제기된 경우에도 관할법원에 이송하여야 한다(가소 13조 3항, 행소 8조 2항, 민소 34조 1항).

한편 원고가 고의 또는 중대한 과실 없이 행정소송으로 제기하여야 할 사건을 민사소송으로 잘못 제기한 경우, 수소법원으로서만 만약 그 행정소송에 대한 관할도 동시에 가지고 있다면 이를 행정소송으로 심리·판단하여야 하고, 그 행정소송에 대한 관할권을 가지고 있지 않다면 그 소송이 이미 행

정소송으로서의 소송요건을 결하고 있음이 명백한 경우가 아닌 이상 관할법원에 이송하여야 한다(대법원 1997. 5. 30. 선고 95다28960 판결).

법률이 특별히 관할위반의 신청을 각하하도록 규정하고 있는 경우를 제외하고는 소 이외의 신청에 있어서도 관할위반의 신청을 각하할 수는 없고 위 규정을 준용하여 관할법원에 이송하여야 한다. 따라서 증거보전, 강제집행, 비송사건 등의 절차에 있어서도 관할을 위반하여 제기된 신청은 이를 각하할 것이 아니라 관할법원에 이송하여야 한다. 다만 지급명령의 신청에 관할위반이 있는 경우에는 신청을 각하하여야 한다(민소 465조, 463조).

소송의 일부만이 관할에 속하지 아니한 경우에는 그 부분만을 이 규정에 의하여 이송하여야 하고 소송의 전부를 이송할 수는 없다. 그러나 관할권이 있는 나머지 소송부분에 대하여도 손해나 지연을 피하기 위한 이송이 필요하다고 인정될 때에는 민사소송법 35조의 규정을 함께 적용하여 소송의 전부를 이송할 수 있을 것이다.

나. 재량에 따른 이송

지방법원 단독판사는 소송에 대하여 관할권이 있는 경우라도 상당하다고 인정하면 직권 또는 당사자의 신청에 따른 결정으로 소송의 전부 또는 일부를 같은 지방법원 합의부에 이송할 수 있다(민소 34조 2항). 소액사건도 이 조항에 의하여 지방법원 합의부로 이송할 수 있다(대법원 1974. 7. 23. 자 74마71 결정). 특히 하급심판결이 서로 엇갈리는 소액사건으로서 대법원판례의 형성이 요구되는 경우에는 앞에서 본 바와 같은 재정합의결정도 가능하지만 재량에 따른 이송도 활용할 수 있을 것이다.

지방법원 합의부는 소송에 대하여 관할권이 없는 경우라도 상당하다고 인정하면 직권으로 또는 당사자의 신청에 따라 소송의 전부 또는 일부를 스스로 심리·재판할 수 있다(민소 34조 3항).

이들 규정은 사물관할과 관련하여 보다 신중을 기할 수 있는 합의부의 심

판권을 확대하려는 취지의 규정이다. 그러나 단독판사의 전속관할에 속하는 소송이나 신청의 경우에는 적용되지 않는다(민소 34조 4항).

다. 손해나 지연을 피하기 위한 이송

법원은 소송에 대하여 관할권이 있는 경우라도 현저한 손해 또는 지연을 피하기 위하여 필요하면 직권 또는 당사자의 신청에 따른 결정으로 소송의 전부 또는 일부를 다른 관할법원에 이송할 수 있다. 다만 전속관할이 정하여진 소의 경우에는 그러하지 아니하다(민소 35조). 심급관할 등의 직분관할도 전속관할이므로 지방법원 항소부의 사건을 이 규정에 의하여 고등법원으로 이송할 수는 없다.

1개의 소에 관하여 관할이 경합하는 때에는 원고는 그 편의에 따라 그중 하나를 선택하여 제소할 수 있는데, 이 경우 제소받은 법원에서 심리하는 것이 공익적 측면에서 보아 소송의 현저한 지연을 초래하거나 사익적 측면에서 보아 피고에게 소송수행상의 지나친 부담으로 현저한 손해를 입게 할 경우에는 이를 피하기 위하여 관할권이 있는 다른 법원에 이송할 수 있게 한 것이며, 그 요건의 판단에 있어서는 손해요건 및 지연요건은 물론 원고 측의 부담도 종합적으로 고려하여야 한다(대법원 1998. 8. 14. 자 98마1301 결정).

수형자가 국가를 상대로 손해배상을 청구한 사안에서, 국가가 수형자의 관리주체로서 부담하는 ‘수형자의 민사소송을 위한 장거리 호송에 소요되는 상당한 인적·물적 비용’은 행정적인 부담이지 소송상대방으로서 부담하는 것이 아니어서, 본조에서 말하는 ‘현저한 손해 또는 지연을 피하기 위한 이송이 필요한 사정’에 해당하지 않는다(대법원 2010. 3. 22. 자 2010마215 결정).

라. 지식재산권 등에 관한 소송의 이송

법원은 특허권등을 제외한 지식재산권과 국제거래에 관한 소가 제기된 경우 직권 또는 당사자의 신청에 따른 결정으로 그 소송의 전부 또는 일부를

민사소송법 2조 내지 23조의 규정에 따른 관할법원 소재지를 관할하는 고등법원이 있는 곳의 지방법원에 이송할 수 있다. 다만 이로 인하여 소송절차를 현저하게 지연시키는 경우나 전속관할이 정하여져 있는 소의 경우에는 그러하지 아니하다(민소 36조 1항, 2항).

지식재산권과 국제거래에 관한 소의 경우 전문재판부 제도의 효용을 높이기 위하여 민사소송법 24조는 특별재판적을 인정하고 있다. 그러나 그와 같이 지식재산권 등에 관한 소에 있어서 특별재판적을 인정하더라도 그 관할은 전속관할이 아니라 임의관할이므로(다만 특허권등의 지식재산권에 관한 소는 민사소송법 2조부터 23조까지의 규정에 따른 관할법원 소재지를 관할하는 고등법원이 있는 곳의 지방법원의 전속관할이다. 이 전속관할에도 불구하고 당사자는 서울중앙지방법원에 특허권등의 지식재산권에 관한 소를 제기할 수 있다. 민소 24조 2항, 3항) 당사자가 그 특별재판적 있는 법원 이외의 법원에 소를 제기하는 것을 막을 수는 없다. 따라서 이러한 경우 특별재판적 있는 법원으로의 이송을 허용하는 근거규정을 두지 않는다면 위와 같은 특별재판적을 인정하는 취지가 몰각될 우려가 있다. 그리하여 민사소송법 36조 1항은 지식재산권과 국제거래에 관한 소의 경우 법원의 직권 또는 당사자의 신청에 의하여 특별한 요건 없이 그 소송의 전부 또는 일부를 위와 같이 특별재판적이 있는 법원으로 이송할 수 있도록 특례를 인정하고, 다만 그 이송으로 인하여 소송절차가 크게 지연될 경우나 전속관할이 정하여져 있는 소의 경우에는 이송할 수 없도록 규정하고 있다.

한편 민사소송법 36조 3항은 특허권등의 지식재산권에 관한 소를 관할하는 법원(민사소송법 24조 2항의 규정에 따른 전속관할법원 또는 3항의 규정에 따른 서울중앙지방법원)은 현저한 손해 또는 지연을 피하기 위하여 필요한 때에는 직권 또는 당사자의 신청에 따른 결정으로 소송의 전부 또는 일부를 민사소송법 2조부터 23조까지의 규정에 따른 지방법원으로 이송할 수 있도록 규정하고 있다.

3. 이송의 절차

가. 신 청

이송은 법원이 직권 또는 당사자의 신청에 의하여 할 수 있으나, 관할위반을 이유로 하는 경우에는 당사자의 신청권이 인정되지 않는다. 따라서 당사자가 관할위반을 이유로 하여 이송신청을 한 경우에도 이는 단지 법원의 직권발동을 촉구하는 의미밖에 없는 것이므로, 법원은 이러한 이송신청에 대하여 재판을 할 필요가 없고, 설령 법원이 이송신청을 거부하는 재판을 하였다 하여도 항고는 물론 특별항고도 허용되지 않는다(대법원 1993. 12. 6. 자 93마524 전원합의체 결정, 대법원 1996. 1. 12. 자 95그59 결정). 당사자에게 이송신청권이 인정되지 않는 이상 항고심에서 당초의 이송결정이 취소되었다 하더라도 이에 대한 신청인의 재항고는 허용되지 않는다(대법원 2018. 1. 19. 자 2017마1332 결정).

소송의 이송신청을 하는 때에는 신청의 이유를 밝혀야 하고, 그 신청은 기일에 출석하여 하는 경우가 아니면 서면으로 하여야 한다(민소규 10조).

재량에 따른 이송과 손해나 지연을 피하기 위한 이송의 신청서에는 1,000원의 인지를 붙여야 하고(인지 9조 5항 4호), 신청사건(사건부호 ‘카기’)으로 접수하여 별책으로 기록을 만든다.

관할위반에 따른 이송신청서에는 인지를 붙일 필요가 없고(인지 10조 단서), 사건부호를 따로 부여하지 아니하며, 그 신청서는 본안기록에 그대로 가철한다(인지액·편철방법예규).

나. 재 판

이송 여부의 재판은 결정에 의한다. 재량에 따른 이송신청, 손해나 지연을 피하기 위한 이송신청, 지식재산권 등에 관한 이송신청이 있는 때에는 법원은 결정에 앞서 상대방에게 의견을 진술할 기회를 주어야 한다. 법원이 직권으로 위와 같은 이송결정을 하는 때에도 당사자의 의견을 들을 수 있다(민소

규 11조).

관할위반에 따른 이송신청은 문건으로 전산입력할 사항이므로 그에 대한 결정문에는 본안사건의 번호를 기재할 것이고, 반면 재량에 따른 이송신청, 손해나 지연을 피하기 위한 이송신청, 지식재산권 등에 관한 이송신청은 신청사건으로 전산입력할 사항이므로 그에 대한 결정문에는 신청사건의 번호를 기재하되, 이송결정을 할 경우 그 주문에 다음과 같이 본안사건의 번호를 표시한다(소송이송신청사건의 결정문에 기재할 사건번호에 관한 예규).

[주문례]

이 법원 20○○가합○○○○ 대여금 사건을 ○○지방법원으로 이송한다.

이송결정과 이송신청의 기각결정에 대하여는 즉시항고를 할 수 있으므로(민소 39조, 다만 관할위반에 따른 이송신청을 기각한 경우에는 앞서 설명한 바와 같이 항고가 허용되지 않는다), 그 결정은 당사자에게 송달하여야 한다. 아울러 재량에 따른 이송신청 및 손해나 지연을 피하기 위한 이송신청에 대한 결정은 그 결정정본을 본안소송기록에 편철해 두어야 한다(인지액·편철방법예규 4조).

소송을 이송받은 법원은 이송결정에 따라야 하고, 이송받은 사건을 다시 다른 법원에 이송하지 못한다(민소 38조). 이송결정의 기속력은 원칙적으로 전속관할을 위반한 경우에도 미치지만, 심급관할을 위반한 이송결정의 기속력은 이송받은 같은 심급의 법원과 하급심 법원에만 미치고 상급심 법원에는 미치지 아니하므로 이송받은 상급심 법원은 사건을 관할법원에 이송하여야 한다(대법원 1995. 5. 15. 자 94마1059 결정, 대법원 2000. 1. 14. 선고 99두 9735 판결).

이송결정이 확정된 때에는 소송은 처음부터 이송받은 법원에 계속된 것으로 본다(민소 40조 1항). 따라서 재심의 소가 재심제기기간 내에 제1심법원에

제기되었으나 재심사유 등에 비추어 항소심판결을 대상으로 한 것이라 인정되어 위 소를 항소심법원에 이송한 경우, 재심제기기간의 준수 여부는 제1심법원에 제기된 때를 기준으로 할 것이고 항소심법원에 이송된 때를 기준으로 할 것이 아니다(대법원 1984. 2. 28. 선고 83다카1981 전원합의체 판결).

법원은 소송의 이송결정이 확정된 뒤라도 급박한 사정이 있는 때에는 기록을 보내기 전까지는 직권으로 또는 당사자의 신청에 따라 필요한 처분을 할 수 있다(민소 37조).

다. 기록 송부

이송결정이 확정되면 이송결정을 한 법원의 법원사무관등은 그 결정의 정본을 소송기록에 붙여 이송받을 법원에 보내야 한다(민소 40조 2항). 일부 이송의 경우에는 소송기록의 등본을 작성하여 송부할 것이나, 이송하지 않는 부분의 관계서류가 적을 때에는 그에 대한 등본을 작성하여 보유하고 기록원본을 송부하여도 무방할 것이다. 기록송부절차에 관한 자세한 설명은 제7장(문서의 작성, 사건기록의 편성·관리 및 보고사무) 제3절 참조.

제4장

제척 · 기피 · 회피

제1절 총 설 76

제2절 제 척 77

제3절 기 피 81

제4절 회 피 87

제5절 법원사무관등에 대한 제척 · 기피 ·
회피 88

제1절 총 설

헌법과 법원조직법은 재판의 적정과 공정을 보장하기 위하여 법관의 자격을 법률로 정하고, 법관은 헌법과 법률에 의하여 그 양심에 따라 독립하여 심판하도록 하는 한편, 법관의 신분을 보장하고, 재판의 심리와 판결은 공개하도록 하고 있다(헌법 101조 3항, 103조, 106조, 109조, 법조 41조 내지 52조). 그러나 그러한 추상적 규정만으로 재판의 공정성이 모두 보장되는 것은 아니므로, 민사소송법은 법관 등이 자기가 담당하는 구체적 사건과 인적·물적으로 특수한 관계에 있는 경우에 그 사건의 직무집행에서 배제되는 제도로써 제척·기피·회피제도를 두고 있다.

제척은 법률이 정하는 사유가 있으면 당연히 직무를 행사할 수 없는 제도이고, 기피는 당사자의 신청이 있을 때 재판에 의하여 직무집행을 못하게 하는 제도이며, 회피는 법관 자신이 자발적으로 직무를 집행하지 않는 제도이다.

제척·기피·회피제도는 법관을 중심으로 규정하였지만 법원사무관등에 대하여도 준용된다(민소 50조 1항).

법관의 중립성을 보장하기 위해 제척·기피·회피제도 외에 여러 공직자에게 공통적으로 적용되는 아래의 제도도 도입되어 있다.

공직자의 이해충돌 방지법은 공직자인 법관이 사건의 당사자 또는 그 대리인이 사적이해관계자임을 안 경우에는 안 날로부터 14일 이내에 소속기관장인 법원장에게 그 사실을 서면으로 신고하고 회피를 신청하도록 규정하고 있다(이해충돌방지법 5조 1항). 여기서 사적이해관계자란 ① 법관 자신 또는 그 가족, ② 법관 자신 또는 그 가족이 임원·대표자·관리자·사외이사로 재직하고 있는 법인·단체, ③ 법관 자신이나 그 가족이 대리하거나 고문·자문 등을 제공하는 개인이나 법인·단체, ④ 법관으로 임용되기 전 2년 이내에 재직하였던 법인·단체, ⑤ 법관으로 임용되기 전 2년 이내에 대리하거나 고문·자

문 등을 제공하였던 개인이나 법인·단체, ⑥ 법관 자신 또는 그 가족이 단독으로 또는 합산하여 발행주식 총수의 30%, 출자지분 총수의 30% 이상 또는 자본금 총액의 50% 이상을 소유하고 있는 법인·단체 등을 말한다(2조 6호 각 목, 이해충돌방지법시행령 3조 1항). 특히 현재는 5년 이상 변호사 등의 직에 있던 사람만이 법관이 될 수 있으므로(법조 42조 2항), 법관으로 임용되기 전 2년 이내 근무한 법무법인 등이 소송대리인으로 선임되는 경우가 더러 있으니 주의가 필요하다. 법원장은 직무를 수행하는 법관을 대체하기가 지극히 어려운 경우, 공익 증진을 위하여 직무수행의 필요성이 더 큰 경우에는 법관이 계속 그 사건을 심리할 수 있도록 할 수 있다(이해충돌방지법 7조 2항).

대법원 공직자윤리위원회의 권고의견 8호는 ① 법관의 배우자나 4촌 이내의 친족이 법무법인 등에 변호사로 근무하는 경우이거나 4촌을 넘는 친족이 법무법인 등의 담당변호사인 경우에는 법관은 해당 법무법인 등이 수임한 사건을 처리하지 않는 것이 바람직하나, ② 그 3·4촌 친족이 법무법인 등의 담당변호사가 아니고 단지 고용관계에 있는 소속 변호사인 경우에는 여러 사정을 고려하여 재판의 공정성에 대한 우려가 없는 경우에는 해당 법무법인 등이 수임한 사건을 처리할 수도 있고, ③ 4촌을 넘는 친족이 법무법인 등의 담당변호사가 아닌 소속 변호사인 경우에는 원칙적으로 해당 법무법인 등이 수임한 사건을 처리하는 것이 가능하지만 여러 사정을 고려하여 재판의 공정성에 의심이 예상되는 경우에는 이를 처리하지 않는 것이 바람직하다고 하고 있다.

제2절 제척

1. 의의

‘제척’이란 법관이 구체적인 사건에 관하여 법률이 정하는 특수한 관계가

있는 경우에 법률상 당연히 그 사건에 관한 직무집행으로부터 제외되는 제도를 말한다. 따라서 사건배당 단계에서 어느 사건에 관하여 어느 법관에게 제척이유가 있음을 안 때에는 그 법관에게 그 사건이 배당되지 않도록 유의하여야 한다. 제척이유에 해당하는 법관이 소송에 관여한 때에는 제척의 재판이 없었더라도 그 판결에는 절대적 상고이유가 있게 되고(민소 424조 1항 2호) 판결이 확정되어도 재심사유에 해당한다(451조 1항 2호). 그러한 의미에서 제척의 재판은 확인적 재판이지 형성적 재판이 아니다.

2. 이 유

- (1) 법관 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 사건의 당사자가 되거나, 사건의 당사자와 공동권리자·공동의무자 또는 상환의무자의 관계에 있는 때(민소 41조 1호)

여기서 당사자란 원고, 피고뿐만 아니라 널리 해석하여 보조참가인이라든가 판결의 기판력이나 집행력이 미칠 모든 소송관계인을 포함한다. 또 공동권리자·공동의무자 또는 상환의무자의 관계란 비록 판결의 기판력이 미치지 않더라도 소송목적인 권리관계에 관하여 공유자, 합유자, 연대채권자 또는 연대채무자, 보증인, 매매에 의한 담보책임자인 관계에 있는 것을 가리킨다.

중증규약을 개정한 중증총회 결의에 대한 무효확인의 소가 제기되었는데 재판부를 구성한 판사 중 1인이 그 중증의 구성원이라면, 그 판사는 당사자와 공동권리자·공동의무자의 관계에 있는 경우에 해당한다(대법원 2010. 5. 13. 선고 2009다102254 판결).

- (2) 법관이 당사자와 친족의 관계에 있거나 그러한 관계에 있었을 때(민소 41조 2호)
친족의 범위는 민법 767조, 777조에 따라 정해진다.

- (3) 법관이 사건에 관하여 증언이나 감정을 하였을 때(민소 41조 3호)

- (4) 법관이 사건당사자의 대리인이었거나 대리인이 된 때(민소 41조 4호)

여기서 대리인이란 소송상의 대리인(법정대리인 또는 소송대리인)을 뜻하며

소송외의 거래에 관한 대리인으로 관여한 것은 포함되지 않는다.

(5) 법관이 불복사건의 이전심급의 재판에 관여하였을 때(민소 41조 5호)

이를 실무상 ‘전심관여’라고 부르기도 하는데, 실무상 가장 많이 문제 되는 제척이유이다.

여기서 ‘이전심급의 재판’이란 상소에 의하여 상소심의 심판대상이 되어 있는 하급심의 재판(종국판결뿐 아니라 중간판결 포함)만을 가리킨다. 따라서

① 재심에서 재심대상이 된 확정판결(대법원 1978. 7. 6. 자 78마147 결정), ② 청구이의의 소에서 그 대상이 된 확정판결, ③ 본안소송에 대한 관계에서 가압류·가처분의 재판, ④ 집행문부여에 대한 이의의 소에 따른 강제집행정지 신청에서 그 대상이 된 판결(대법원 1969. 11. 4. 자 69그17 결정), ⑤ 본안소송의 재판장에 대한 기피신청사건의 재판(대법원 1991. 12. 27. 자 91마631 결정) 등은 여기에서의 이전심급의 재판에 해당하지 않는다. 또한 민사특별절차(지급명령신청사건, 조정신청사건 등)나 소액사건에서 지급명령이나 조정을 갈음하는 결정 또는 이행권고결정에 대하여 상대방이 이의하여 소송절차 내지 변론절차로 이행된 경우에 위 지급명령 등이 ‘이전심급의 재판’에 해당되지 않음은 물론이다. 상고심에서 파기환송이나 파기이송된 경우에 환송이나 이송을 받은 법원에 대한 관계에서 그 환송·이송 전의 원심(항소심)재판은 여기에서의 이전심급의 재판에 해당하지 않으나 이에 관하여는 별도의 제척규정이 있다(민소 436조 3항). 이에 비하여 항소심에서의 취소환송, 취소이송의 경우에는 별도의 제척규정이 없고 그 환송·이송 전의 제1심이 이전심급에 해당하지도 않으므로 결국 환송·이송 전의 제1심에 관여한 것이 환송이나 이송 후 재판에서의 제척이유에 해당하지 않는다고 볼 것이다. 어떤 사건의 사실관계와 관련이 있는 다른 형사사건에 관여한 것이 전심관여에 해당한다고 할 수 없다(대법원 1985. 5. 6. 자 85두1 결정).

한편 여기서 ‘관여’란 이전심급의 최종변론과 판결의 합의에 관여한 경우를 말하므로 변론 종결 당시가 아닌 변론에 관여하여 소송지휘, 증거 채부의

재판, 증거조사 등을 한 것에 그치거나(대법원 1994. 8. 12. 선고 92다23537 판결) 판결의 선고에만 관여한 경우는 이에 포함되지 않는다. 다른 법원으로 부터 촉탁을 받고 그 사건에 관한 직무를 행한 경우도 이에 포함되지 않는다(민소 41조 5호 단서).

3. 절 차

가. 직권에 의한 제척의 재판

제척의 이유가 있는 때에는 법원은 직권으로 또는 당사자의 신청에 따라 제척의 재판을 하여야 하는데(민소 42조), 제척의 이유가 있다고 인정되면 해당 법관은 후술하는 회피를 하는 경우가 대부분이므로 실제로 직권으로 제척의 재판을 하는 경우는 거의 없다. 다만 회피에 관하여 필요한 감독권자의 허가(49조)가 거부된 경우 등에는 직권에 의한 제척의 재판이 이루어질 수도 있을 것이다.

직권에 의한 제척재판의 절차는 해당 법관 자신 또는 같은 재판부 소속의 다른 법관의 요청에 의하여 개시된다는 점을 제외하고는 신청에 의한 제척재판의 절차와 같다고 설명되고 있다. 따라서 해당 법관을 제외한 다른 법관으로 구성된 합의부에서 관할하게 된다(민소 46조 1항, 2항). 요청서나 재판서(결정서) 등 관계서류는 본 소송기록에 가철하여야 한다.

나. 신청에 따른 제척의 재판

당사자는 특정 법관을 지정하여 제척의 신청을 할 수 있다. 그러나 법관이 사건에 관하여 제척이유에 해당하는 일 자체가 드물 뿐 아니라 만약 그러한 이유가 있을 경우에는 해당 법관이 미리 회피하는 것이 대부분이므로 제척신청 역시 실무에서는 극히 드물다고 할 수 있다. 다만 제척이유 유무에 관하여 법관과 당사자가 의견을 달리하는 경우에는 제척신청이 있을 수 있다.

제척신청의 방식과 처리절차는 후술하는 기피신청의 경우와 같다(민소 44

조). 다만 기피신청에 관하여는 신청의 시기에 제한이 있으나(43조 2항), 제척신청의 경우에는 그러한 제한이 없다.

제척 재판의 주문례는 다음과 같다.

[주문례]

판사 ○○○를 ○○지방법원 20○○가합○○○○ 대여금 사건의 직무집행으로부터 제척한다.

제4장

제척
·
기 피
·
회 피

제3절 기 피

1. 의 의

‘기피’란 제척이유 이외에 법관에게 재판의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에 당사자의 신청을 기다려 그 법관을 직무집행으로부터 제외시키는 제도이다. 따라서 기피의 재판은 제척의 재판과 달리 형성적 재판에 해당한다.

2. 이 유

제척이유를 제외한 다른 이유로서 재판의 공정을 기대하기 어려운 사정이 기피의 이유에 해당한다(민소 43조 1항).

형사소송에서는 제척원인이 규정되어 있을 뿐 제척신청제도가 존재하지 않으므로 당사자가 제척원인을 주장하는 경우에도 기피신청을 하도록 규정되어 있으나(형소 18조), 민사소송에서는 이와 달리 제척이유 이외의 이유만이 기피신청의 이유가 된다.

기피이유인 ‘법관에게 공정한 재판을 기대하기 어려운 사정이 있는 때’란 우리 사회의 평균적인 일반인의 관점에서 볼 때, 법관과 사건과의 관계, 즉 법관과 당사자 사이의 특수한 사적 관계 또는 법관과 해당 사건 사이의 특

별한 이해관계 등으로 인하여 법관이 불공정한 재판을 할 수 있다는 의심을 할 만한 객관적인 사정이 있고, 그러한 의심이 단순한 주관적 우려나 추측을 넘어 합리적인 것이라고 인정될 만한 때를 말한다(대법원 2019. 1. 4. 자 2018스563 결정). 그러나 당사자가 불공평한 재판이 될지도 모른다고 추측할 만한 당사자의 주관적인 의혹만으로는 기피이유에 해당하지 않는다. 따라서 재판장의 소송지휘에 관한 당사자의 불만, 소송당사자 일방이 재판장의 변경에 따라 소송대리인을 교체한 것(대법원 1992. 12. 30. 자 92마783 결정), 법관이 다른 당사자 사이의 동일한 내용의 다른 사건에서 당사자에게 불리한 법률적 의견을 표시한 것(대법원 1993. 6. 22. 선고 93재누97 판결), 담당 재판부가 신청에 따른 증거채택을 일부 취소하였다는 사정(대법원 1993. 8. 19. 자 93주21 결정), 기피신청 후에 소송절차를 정지하지 않고 변론기일을 진행한 것(대법원 2016. 11. 10. 자 2016마1010 결정) 등은 기피이유가 되지 않는 것이 보통이다.

3. 절 차

가. 신 청

(1) 법관에 대한 기피는 그 이유를 밝혀 신청하여야 하며, 합의부의 법관에 대한 기피는 그 합의부에, 수명법관·수탁판사 또는 단독판사에 대한 기피는 해당 법관에게 신청하여야 한다(민소 44조 1항). 신청은 서면 또는 말로 할 수 있다(161조).

(2) 기피의 이유와 소명방법은 신청한 날부터 3일 이내에 서면으로 제출하여야 한다(민소 44조 2항). 서면에 의하지 아니한 소명방법은 제출이 허용되지 않는다. 기피의 이유가 해당 법원의 사건기록상 명백한 사항, 즉 법원에 현저한 사실을 내용으로 하는 경우에는 기피신청인이 그 사실을 소명할 필요는 없다(대법원 1988. 8. 10. 자 88두9 결정).

(3) 신청의 시기에 관하여는 제한이 있다. 만약 당사자가 법관을 기피할

이유가 있다는 것을 알면서도 본안에 관하여 변론하거나 변론준비기일에서 진술을 한 경우에는 기피신청을 하지 못한다(민소 43조 2항).

(4) 기피신청이 있을 경우에는 신청사건으로 전산입력하고, 기록은 별도 기록으로 따로 만들되 본안소송기록에 첨부하여야 한다(인지액·편철방법예규). 말로 신청한 경우에는 그 신청을 기재한 조서의 원본 또는 등본(본안의 변론조서에 신청을 기재한 경우)을 그 기록에 첨부하여야 한다.

제4장

제척·기피·회피

나. 신청과 본안절차의 정지

(1) 기피신청이 있는 경우에는 그 신청에 대한 재판이 확정될 때까지 본안 소송절차를 정지하여야 한다(민소 48조 본문). 다만 다음과 같은 경우에는 그러하지 아니하다(단서).

① 종국판결의 선고

기피신청이 있더라도 종국판결의 선고는 할 수 있으므로, 변론 종결 후에 기피신청이 있다 하더라도 이를 무시하고 판결을 선고하여도 위법이 아닐 뿐 아니라(대법원 1993. 11. 9. 선고 93다39553 판결), 그 판결선고에 뒤이은 항소제기와 항소심의 소송절차를 정지하지 아니하여도 위법이 아니다(대법원 1966. 5. 24. 선고 66다517 판결).

② 긴급을 요하는 행위

긴급을 요하는 행위란 그 행위를 지연하면 상대방이 회복할 수 없는 손해를 입게 되는 행위를 말한다. 예컨대 증거보전행위, 멸실의 염려가 있는 증거조사의 시행, 집행정지명령, 가압류·가처분의 발령 등이다.

③ 기피신청이 각하된 경우

뒤에서 설명하는 바와 같이 분명한 소송지연의 목적 또는 기피신청의 방식 위배 등을 이유로 기피신청이 각하된 경우를 말한다.

(2) 소송절차를 정지하여야 함에도 소송행위를 한 경우에 그 소송행위는 위법하지만 그 후에 기피신청 기각결정이 있는 때에는 흠이 치유되어 적법

하게 된다(대법원 1978. 10. 31. 선고 78다1242 판결).

그러나 기피신청이 있는 후 그에 대한 각하결정을 고지하기 전에 변론기일을 진행하여 쌍방불출석으로 처리하는 행위는 민사소송법 48조를 위반한 절차상 흠이 있고, 특별한 사정이 없는 이상 그 후 기피신청 각하결정이 그대로 확정되었다는 사정만으로는 위 절차 위반의 흠이 치유된다고 할 수 없다(대법원 2010. 2. 11. 선고 2009다78467 판결). 다만 법원이 기피신청을 받았음에도 소송절차를 정지하지 아니하고 변론을 종결하여 판결선고기일을 지정하였다고 하더라도 종국판결에 대한 불복절차에 의하여 그 당부를 다룰 수 있을 뿐 이에 대하여 별도로 항고로써 불복할 수 없다(대법원 2000. 4. 15. 자 2000그20 결정).

다. 재 판

(1) 기피신청을 받은 법원 또는 법관에 의한 각하결정(간이각하)

기피권의 남용을 막기 위하여 다음의 경우 기피신청을 받은 법원이나 법관 스스로 결정으로써 신청을 각하하여야 한다.

① 신청이 민사소송법 44조의 규정에 어긋난 경우(민소 45조 1항 전단)

예컨대 이유를 밝히지 않고 기피신청을 하였거나 소정기간 내에 소명방법을 서면으로 제출하지 않았거나 수명법관에 대한 기피신청을 해당 법관 아닌 소속 합의부에 대하여 한 경우 등이다.

② 신청이 소송의 지연을 목적으로 하는 것이 분명한 경우(민소 45조 1항 후단)

재판의 공정을 보장하기 위하여 당사자에게 법관을 기피할 권리가 보장되는 것으로서 당사자는 이러한 기피권을 성실하게 행사할 의무(민소 1조)가 있기 때문에 소송지연을 목적으로 하는 기피권 행사는 신의칙에 반한다. 예컨대 새로운 기피이유가 없음에도 기피신청을 반복하거나 재판장의 소송지휘에 관한 주관적 불만을 기피이유로 비약시켜 기피신청을 하는 경우 등이

이에 해당할 것이다. 원고의 기피신청이 소송의 지연을 목적으로 하는 것이 분명한 경우에 해당하여 기피신청이 각하된 경우, 위 기피신청 전후로 지정된 변론기일에 원고가 세 차례 불출석하여 본안사건이 취하간주로 종결된 이상 위 기피신청을 각하한 결정에 대하여 재항고로 다룰 이익이 없다(대법원 2022. 4. 8. 자 2022마9 결정).

(2) 합의부에 의한 재판

① 의견서의 작성

기피를 당한 법관은 그 기피신청이 앞서 본 바와 같은 이유로 각하된 경우를 제외하고는 그 기피신청에 대한 의견서를 작성하여 제출하여야 한다(민소 45조 2항). 실무상 그 의견은 극히 간단히 추상적으로만 기재하여 기피신청기록에 편철하는 것이 보통이다. 법관기피신청사건에서 민사소송법 45조 2항의 규정에 따라 기피신청을 당한 법관의 의견서에 대하여 판단하지 아니하고, 46조 2항 단서의 규정에 따른 그 법관의 의견진술절차를 거치지 않더라도 심리미진의 위법이 있는 것은 아니다(대법원 1992. 12. 30. 자 92마 783 결정).

② 담당재판부의 결정

기피신청의 당부에 대한 재판은 기피신청을 당한 법관의 소속 법원 합의부에서 결정으로 재판하는데(민소 46조 1항), 기피신청을 당한 법관 자신은 이 재판에 관여하지 못한다(2항). 따라서 합의부가 여럿인 법원에서는 어느 합의부 법관에 대한 기피신청사건의 담당은 다른 합의부라고 사무분담으로 정하여 놓는 경우가 많다. 만약 기피신청을 당한 법관을 제외하고는 소속법원이 합의부를 구성하지 못하는 경우에는 바로 위의 상급법원(조직법상 의미)의 합의부가 담당하게 된다(3항). 따라서 지방법원 지원의 경우에는 고등법원이 아니라 지방법원 본원이 바로 위의 상급법원에 해당한다.

③ 인용결정을 할 경우

기피신청을 이유 있다고 하는 재판의 주문례는 다음과 같다.

[주문례]

○○지방법원 20○○가합○○○○ 대여금 사건에 관하여 판사 ○○○에 대한 기피는 이유 있다.

④ 각하결정 또는 기각결정을 할 경우

기피당한 법관이 재배당 등으로 그 사건에 관하여 직무를 집행할 수 없게 된 경우, 민사소송법 48조 단서의 규정에 의하여 본안사건에 대하여 종국판결이 선고되거나 소송절차가 정지되지 않은 채 진행된 결과 본안사건이 종국처리된 경우에는 기피신청을 유지할 이익 내지 목적이 없게 되어 기피신청을 각하하여야 한다(대법원 1988. 10. 12. 자 88주2 결정, 대법원 2008. 5. 2. 자 2008마427 결정).

기피신청이 이유 없는 경우에는 그 기피신청을 기각하는 결정을 한다.

라. 불복

기피신청에 정당한 이유가 있다는 결정에 대하여는 불복할 수 없다(민소 47조 1항). 기피신청을 받은 법원 또는 법관의 각하결정(45조 1항) 또는 기피신청이 이유 없다는 결정(46조 1항)에 대하여는 즉시항고를 할 수 있다(47조 2항). 민사소송법 45조 1항의 각하결정에 대한 즉시항고에는 집행정지의 효력이 없으므로(47조 3항) 원심법원은 즉시항고에 관계없이 소송절차를 진행할 수 있다. 소송촉진을 도모하기 위한 것이다. 이 점에서 기각결정에 대한 즉시항고의 경우와 구별된다.

기피신청의 대상이 지방법원 항소부 소속 법관이고 소속 법원의 다른 합의부에서 기피신청을 각하 또는 기각하는 결정은 항소법원의 결정과 같은 것으로 보아야 하므로 이 결정에 대하여는 대법원에 재항고하는 방법으로 다투어야 한다(대법원 2008. 5. 2. 자 2008마427 결정). 기피신청에 대한 각하 또는 기각결정에 대한 즉시항고를 항고심이 각하, 기각하였으면 그에 대한 재항

고는 즉시항고로서의 성격을 가진다(대법원 2007. 7. 2. 자 2006마409 결정).

제4절 회 피

‘회피’란 법관이 스스로 제척 또는 기피의 이유가 있다고 인정하여 자발적으로 특정사건의 직무집행을 피하는 제도를 말한다(민소 49조). 이 경우에는 별도의 재판을 요하지 않으며 감독권이 있는 법원의 허가만 받으면 된다. 이 점에서 회피에 관하여 해당 법관의 신청과 합의부의 재판을 요하는 형사소송의 경우와 크게 다르다(형소 24조 3항, 21조).

여기서 ‘감독권이 있는 법원’이란 사법행정상의 감독권을 가지는 법관(법원장, 지원장 등)을 가리킨다고 해석된다. 회피의 허가는 사법행정상의 처분일 뿐 재판이 아니므로 그 후에 소송행위를 하는 일이 있어도 그 행위의 무효나 취소문제가 생기지 않는다.

실무에서는 이러한 감독권자의 허가에 의한 회피의 절차가 사건배당 절차와 관련된 재배당 절차에 흡수되어 한꺼번에 행하여지는 경우가 대부분이며, 재배당으로부터 분리된 순수한 회피절차는 거의 행해지지 않고 있다. 회피에 관한 허가권자와 사건재배당의 주관자가 동일하므로 이러한 실무처리는 타당하다고 할 수 있다.

이 경우 재배당 사유는 ‘배당된 사건을 처리함에 현저히 곤란한 사유가 있어서 재판장이 그 사유를 기재한 서면으로 재배당 요구를 한 때’(사무분담·사건배당예규 14조 4호)가 된다. 구체적인 재배당 절차에 관하여는 제6장(접수사무) 제4절 참조.

제5절 법원사무관등에 대한 제척·기피·회피

민사소송법은 법관에 관한 제척·기피·회피 규정을 법원사무관등에게 준용한다(민소 50조 1항). 따라서 심판에 참여하는 법원사무관등에게 사무처리의 공정을 저해할 일정한 이유(41조 각 호)가 있을 때에는 당연히 직무집행에서 제척되고, 법원사무관등에게 직무집행의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있다고 생각하는 당사자는 신청에 의하여 그 법원사무관등을 기피할 수 있다(43조). 법원사무관등 역시 자신에게 위와 같은 제척이유나 기피이유가 있다고 생각하면 스스로 사무집행을 회피하여야 한다(49조).

법원사무관등에 대한 제척·기피신청에 대한 재판은 그가 속한 법원이 결정하는 것으로 규정되어 있으므로(민소 50조 2항), 법관에 대한 제척·기피 재판과 달리 단독판사가 재판함이 원칙이고(법조 7조 4항), 예외적으로 합의부가 심판할 것을 스스로 결정한 때에는 합의부가 재판할 수 있다(32조 1항 1호). 다만 합의부에 참여하는 법원사무관등의 경우에는 합의부가 재판하는 것이 바람직할 것이다. 반면 사법보좌관에 대한 제척 또는 기피의 재판은 소속 법원의 합의부가 결정으로 하여야 한다(사법보좌관규 9조 2항).

제척원인이 있는 법원사무관등이 작성한 조서는 증명력이 인정되지 않고 그 직무집행행위는 모두 위법하며 특히 그것이 판결에 영향을 미쳤다면 상고이유가 된다(민소 423조).